Signature Not Verified
Assinado por MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES em 26/08/2010 22:50:39.373 GMT-03:00

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FRANQUIAS POSTAIS DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.615.555/0001-64, com sede na Rua Helena Piekarski Pinto, n.º 674, Fazenda Velha, Araucária – Paraná, CEP 83704-650, por seus advogados adiante firmados, estabelecidos com escritório profissional no endereço abaixo impresso, onde recebem intimações e notificações, vem à presença de Vossa Excelência, respeitosamente, apresentar:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE c/c preceito cominatório de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM CARATER CAUTELAR

Em face da DECLARAÇÃO de constitucionalidade das regras contidas no artigo 6°, incisos III e IV, artigo 7°, parágrafo único e artigo 10° da Lei 11.668/2008 – que dispõe sobre o exercício da atividade de franquia postal.

DA DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

O advogado, Marcelo Arthur Menegassi Fernandes, inscrito na OAB-PR 31.367, que abaixo subscreve, declara para os devidos fins e sob as penas da Lei que os documentos ora juntados são fotocópia fidedigna dos documentos originais, bem como, as fotocópias digitais da Lei 11.668/2008 e do Decreto 6.639/2008 foram extraídas on line, do sitio do Senado Federal – Portal legislação - texto atualizado, respondendo este advogado cível e criminalmente por quaisquer documentos, ora juntados que não se tratem de fotocópia fidedigna daqueles que foram anexados com a inicial.

Curitiba, 26 de agosto de 2010.

_____

Marcelo Arthur Menegassi Fernandes
OAB-PR 31.367

I) PRELIMINARMENTE

I – a) DA PERTINENCIA TEMÁTICA

Trata-se a presente ADC de discussão acerca da constitucionalidade das normas contidas no artigo 6°, incisos III e IV, artigo 7° e artigo 10° da Lei 11.668/2008.

A autora desta ADC congrega associados, denominados de ACF – Agencia de Correios Franqueadas, que por sua vez, estão submetidos à Lei 11.668/2008 – Lei de Franquia Postal, que tem como objetivo a regularização destes contratos.

Em decorrência da existência de várias ações judiciais em trâmite, seja nas instâncias primárias, seja junto aos Tribunais Regionais e até junto ao Pretório Excelso, discutindo a inconstitucionalidade das regras que contém a atual legislação e, portanto, alcançando os interesses dos franqueados é que se propõe a presente medida judicial.

A Lei 11.668/2008, em seu art. 6°, inc. III e IV determina que:

> *"Art. 6° – São objetivos da contratação da franquia postal:*
>
> *III – **a manutenção e expansão** da rede de Agencia dos Correios Franqueadas, respeitando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e;*
>
> *IV – a melhoria do atendimento prestado à população".*

A Lei determina que a rede de Agencia de Correios Franqueadas – ACF seja mantida e expandida, bem como, o atendimento prestado seja melhorado.

Não obstante, a mesma legislação, conforme a regra contida no caput do artigo 7°, assim determina:

> *"Até que **entrem em vigor** os contratos de franquia postal celebrados de acordo com o estabelecido nesta lei, **continuarão com eficácia aqueles firmados com as Agências de Correios Franqueadas** que estiverem em vigor em 27 de novembro de 2007".*
>
> *Parágrafo único. A ECT tem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de publicação da regulamentação desta lei, editada pelo Pode Executivo, para concluir todas as contratações mencionadas neste artigo".*

Neste diapasão, importante que o Pretório Excelso verifique que a Lei 11.668/2008, quando aprovada pelo poder legislativo, tinha como objetivo a não violação de preceitos fundamentais – garantidos pela Constituição Federal – a manutenção da boa qualidade de um serviço público que é essencial e cuja **atividade auxiliar exercida** pelos franqueados é de suma importância e relevância para evitar prejuízos à Administração Pública, para a Estatal, neste caso para a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Quanto ao parágrafo único, este apenas faz referência a um prazo, para que a Administração Pública tenha tempo para realizar todo

o processo de regularização dos contratos, conforme estipulado pela Lei 11.668/2008, não se tratando de nenhum ato que vise a perpetuação dos franqueados no poder, até pelo fato de que a lei exige que a contratação ficasse subsidiada a Lei de Licitações.

No caso do parágrafo único do artigo 7°, o mesmo é utilizado e interpretado de forma equivocada, não apenas porque deu base para o §2° do art. 9° do Decreto 6.639/2008, mas principalmente em decorrência da interpretação da data da contagem do tempo.

O Pretório Excelso reconhece que a regra contida no artigo 1° §3° da Lei de Introdução do Código Civil assim determina:

> "*Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação*".

Ocorre, que o parágrafo único determina que o prazo começaria a fluir quando da publicação da regulamentação desta lei. O Decreto 6.639/2008 que em tese alega-se sua inconstitucionalidade foi publicado em data de 10/11/2008, portanto o prazo mencionado no parágrafo único de fato findaria em data de 10/11/2010.

Todavia, verdade também que, no que pese a inconstitucionalidade de tal regra, como acusamos na ADI 4437, aqui a mesma serve para definir que a interpretação literal deste prazo está equivocada, pois a regra que regulamenta o parágrafo único do art. 7°, ou seja, o §2° do art. 9° teve o texto alterado pelo Decreto 6.805 de 25 de março de 2009, publicado por sua vez no DOU em data de 26 de março de 2009.

Desta forma, a data correta em que o prazo passou a viger foi a de 26/03/2009, findando o mesmo apenas em data de 26/03/2011.

Fato é que em razão destas distorções jurídicas e interpretações equivocadas que ocorreram violações a preceitos fundamentais, bem como, se tem deflagrado um verdadeiro terrorismo acerca de um apagão postal, proveniente inclusive de uma data errada.

Neste sentido a importância da presente ADC e sua pertinência temática, pois discussões acerca da inconstitucionalidade da Lei

11.668/2008, violam diretamente os direitos dos franqueados, associados da autora.

Ainda, no mesmo norte, a Lei 11.668/2008, normatiza, através do artigo 10°, o que o próprio Pretório Excelso, através da **ADPF 46 - STF** enfatiza que, através do voto do Ministro Carlos Britto, não é possível que o serviço postal, que é de natureza pública seja repassado para o setor privado.

Tal norma (art. 10°) trouxe a lume, desta relação jurídica (ECT x ACF), o que já estabelecido em nossa doutrina e jurisprudência dominante, inclusive junto ao Superior Tribunal de Justiça, que não apenas a **natureza jurídica** de um contrato de franquia e/ou de franquia postal não poderia sofrer **mutação**, mesmo que fosse proveniente de um contrato administrativo, tampouco, tal **atividade auxiliar** poderia ser equiparada à **prestação de serviço público**.

Motivo pelo qual levou a Lei 11.668/2008 a revogar o §1° do art. 1° da Lei 9.074/1995, uma vez que tal atividade auxiliar, de suma importância para a prestação de serviço público realizada pela ECT, jamais poderia ser considerada uma concessão e/ou permissão, decorrente da regra contida no art. 175 da Constituição Federal.

Sendo assim, a Lei de Franquia Postal aponta para a formalização do ato administrativo através da contratação direta, adjudicação direta, fato este que se verifica quando a própria Lei fica subsidiada a Lei 8.666/1993 e em hipótese alguma fica subsidiada às leis 9.074/1995 e 9.648/1998, ou seja, o presente contrato de franquia postal esta submetido a regra prevista no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e não à regra contida no art. 175 da Constituição Federal.

Atenta-se ao fato de que falar-se de adjudicação direta e/ou contratação direta não se trata de **perpetuação** destas franquias no poder, até porque a formalidade do ato que está previsto no art. 116 e demais regras da Lei 8.666/1993 requer as mesmas exigências, todavia sem o processo de licitação na modalidade concorrência, não causando qualquer desequilíbrio, seja para quem detêm o Know How há mais de 17 anos, seja para quem não tem nenhuma experiência.

Oportuno ainda destacar que a Lei 11.668/2008 em momento algum igualou o contrato de franquia postal às concessões ou

permissões e como já amplamente decido pelo Superior Tribunal de Justiça o contrato de franquia é contrato atípico, de conteúdo próprio e a ele não se enquadra, tampouco se assemelha o contrato de prestação de serviço, dos quais se prevê a licitação sob a forma de concessão e/ou permissão.

Considerando que a discussão da inconstitucionalidade de tal norma, pode deturpar a natureza jurídica desta relação jurídica, bem como, o próprio entendimento do Pretório Excelso acerca de quem é detentor da prestação de serviço público postal, ou seja, a ECT e suas Regionais;

Considerando que o tema em apreço, é de interesse direto da autora e seus associados, que tem como objetivo a regularização, via a retidão que se exige, do direito, da justiça e desta Corte Suprema, a quem cabe afastar toda e qualquer deturpação que se tenta implantar em nossas normas legais e constitucionais;

Considerando a inconsistência atual dos atos praticados pela própria ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, inclusive acerca de planos de contingência, cujo custo seria voluptuoso para Administração Pública, e outras Associações sobre um possível apagão postal, sugerindo uma interpretação totalmente divergente do que a Lei de Franquia Postal determinou;

Considerando que tais atos aterrorizam os mais de 1400 franqueados existentes no país, é que entende-se existir o interesse direto desta associação e seus associados com o tema ora abordado objeto desta ADC.

Os direitos de alguns, que hoje são violados, é o nosso direito violado no futuro e a conseqüência é a usurpação do poder conferido ao Pretório Excelso na defesa dos interesses difusos e coletivos, da segurança jurídica, fruto das manobras inconseqüentes e ilegais de quem deveria agir em acordo com a legislação.

I – b) DA LEGITIMIDADE ATIVA

Trata-se a autora de uma associação de caráter nacional que reúne pessoas jurídicas que desenvolvem a mesma atividade, qual seja, a de franquia postal.

Conforme pode se verificar no artigo 2° do Estatuto, Primeira Alteração, consta como prerrogativas da autora:

> ***"Parágrafo Primeiro: Para cumprir suas finalidades sociais, a Associação se organizará em tantas unidades quantas se fizerem necessárias, em todo o território nacional, as quais funcionarão mediante delegação expressa da matriz e se regerão pelas disposições contidas neste estatuto e, ainda, por um regimento interno aprovado pela Assembléia Geral;***
>
> ***Parágrafo segundo: A esta associação nacional poderão se filiar associação de outros estados e municípios, cujos membros que as compõe sejam pessoas jurídicas cuja atividade esteja relacionada com o serviço de franquia postal, bem como, toda e qualquer pessoa jurídica cuja atividade tenha por objetivo o serviço de franquia postal;***
>
> ***Parágrafo terceiro: Esta associação poderá defender os direitos inerentes a sua classe e subclasse em âmbito nacional, conforme regra prevista no art. 103, inc. IX da Constituição Federal".***

A autora esta composta de pessoas jurídicas de uma mesma classe, que por sua vez desempenham a mesma atividade, qual seja, a atividade de franquia postal e estão submetidas ao mesmo tipo de contrato, bem como, vinculadas juridicamente a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Existe no caso visto em tela a **conexão** dos objetivos comuns dos associados que por sua vez comungam de um mesmo interesse, tornando-os assim homogêneos em face do objeto final, pois pretendem alcançar o mesmo sucesso, a mesma justiça, a mesma igualdade e a mesma legalidade, declarando a constitucionalidade da Lei 11.668/2008 e seus respectivos artigos, conforme supramencionado.

Ainda em vista da regra insculpida no **art. 5°, inc. LIV da Constituição Federal**, tratado como principio fundamental, do qual derivam todos os outros princípios, tem-se que o principio do devido processo legal é a garantia do exercício da justiça, do direito de ação, que incentiva a legitimidade da autora na busca do objeto ora pretendido.

Conforme entendimento desta Excelsa Corte, consta no mandato em anexo, os poderes especiais e específicos outorgados para a finalidade supramencionada.

Por fim, no que pese, ainda discutirmos abaixo, a tese acerca da dispensabilidade da comprovação e representatividade em nove ou mais estados da Federação, quando tratar-se de assunto de grande relevância e segurança jurídica, que atraia inclusive a regra contida no art. 12 da Lei 9.868/1999, esta Associação já tem representatividade em nove estados sendo: MARANHÃO, SERGIPE, PARAÍBA, PERNAMBUCO, MINAS GERAIS, SÃO PAULO, PARANÁ, SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL.

I – c) DA LEGITIMIDADE ATIVA INDEPENDENTEMENTE DA REPRESENTATIVIDADE EM NOVE OU MAIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO OBJETO AQUI PRETENDIDO

O entendimento do Pretório Excelso determina que para que uma associação seja reconhecida como sendo de caráter nacional e, por conseguinte tenha legitimidade para propor uma ADC deve ter representatividade em nove ou mais Estados da Federação.

Tal entendimento, que tem como fundamento a Lei Orgânica para constituição dos partidos políticos, passou a ser utilizado de forma generalizada em aproveitamento a toda e qualquer associação de âmbito nacional tendo por objetivo limitar a participação das associações frente ao que reza a regra do art. 103 de nossa Carta Magna sob o prisma de que se tal associação não tem representatividade nacional, também não pode alcançar em tese, os interesses da sociedade como um todo.

Todavia, toda limitação severa, via de conseqüência, com o tempo passa a se **potencializar**, a ponto de interferir no direito constitucional do cidadão, da sociedade, deixando assim de avaliar as peculiaridades de cada caso concreto.

No caso visto em tela, a presente associação quando constituída, não possuía membros em nove estado da Federação, o que ocorreu no decorrer dos processos em que reivindicava direitos que poderiam beneficiar mais de 1400 franqueados em todo o país.

Importante aqui, verificar que em parte a tese que se desenvolve é factível, visto que tanto uma ADC quanto uma ADI, não podem ter seguimento negado em decorrência da legitimidade de uma associação face sua representatividade, principalmente quando se trata de assunto de grande relevância e de segurança jurídica.

Veja este Pretório Excelso, que, quando esta associação ingressou com a ADI 4437, apenas tinha representatividade em dois estados da Federação, todavia, em face da relevância do objeto jurídico abordado, tanto o Presidente desta Excelsa Corte, quanto o Ministro Marco Aurélio, entenderam pelo prosseguimento da ADI.

Apenas dois meses se passaram e esta associação já tem representatividade em nove estados da Federação, quais sejam: MARANHÃO, SERGIPE, PARAÍBA, PERNAMBUCO, MINAS GERAIS, SÃO PAULO, PARANÁ, SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL.

No que pese não ter como associados estes mais de 1400 franqueados, a declaração de constitucionalidade do artigo 6°, incisos III e IV, artigo 7° e artigo 10° da Lei 11.668/2008, visa defender o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, a segurança jurídica e acima de tudo determinar que a Lei 11.668/2008 está correta, é constitucional e não fere o direito das partes envolvidas diretamente, tampouco o direito e interesse de terceiros.

No que pese não ter como associados estes mais de 1400 franqueados, o objeto jurídico aqui pretendido visa construir uma relação jurídica segura, correta e sob a apreciação do Pretório Excelso.

Importante, **mesmo já tendo comprovado a legitimidade em razão da representatividade**, neste mesmo norte estabelecer que nem a Constituição Federal, nem qualquer Lei Ordinária determina que uma associação nacional tenha em seu corpo de associados pessoas estabelecidas em nove ou mais estados da Federação.

Da mesma forma a presunção análoga de que esta representatividade se opere frente à permanência de um representante em cada estado, num total de nove, não lhe dá a condição de pessoa jurídica, associação, que potencialmente poderia representar os interesses de uma coletividade, da sociedade.

Necessário então que a avaliação desta representatividade ocorra de forma menos superficial, ou seja, não apenas no **plano físico, espacial**, da existência de um representante em cada estado, mas sim de forma mais aprofundada, verificando o conteúdo do pedido e as conseqüências do mesmo em relação a todos que se encontram sediados pelos Estados da Federação.

Veja, esta Excelsa Corte, que no caso em apreço, temos medidas judiciais em todo o país, promovida por sindicatos estaduais e pelos próprios franqueados, impugnando o edital de licitação por irregularidades e por inexigibilidade de se licitar na modalidade concorrência.

Conforme demonstra o quadro sinóptico abaixo é possível verificar o resultado destas demandas até o presente momento:

Importante aqui verificar que muitas ações individuais não estão contabilizadas, o que por certo eleva o número de demandas e resultados consideravelmente.

QUADRO SINOPTICO REFERENTE AOS PROCESSOS JUDICAIS QUE DISCUTEM O EDITAL DE LICITAÇÃO DAS AGF

ESTADO	Nº DE AÇÕES	AÇÕES			Nº CONCORRENCIAS	SITUAÇÃO DAS AÇÕES
		DEFERIDAS	INDEFERIDAS	SEM JULGAMENTO		
AC	**00**	-	-	-	03	Não houve ação judicial.
AL	**03**	00	03	00	14	Nenhuma ação deferida.
AM	**01**	00	00	01	02	Nenhuma ação deferida.
BA	**24**	04	18	02	35	Suspensão de 04 Concorrências.
CE	**03**	02	00	01	09	Suspensão de 08 Concorrências.
DF	**03**	01	01	01	11	Suspensão de TODAS as Concorrências.
ES	**21**	07	12	02	23	Suspensão de 07 Concorrências.
GO/TO	**03**	01	02	00	35	Suspensão de 01 Concorrência.
MG	**07**	02	02	01	146	Suspensão de TODAS as Concorrências.
MS	**00**	-	-	-	04	Não houve ação judicial.
MT	**01**	00	01	00	15	Nenhuma ação deferida.
PA/AP	**10**	00	02	08	24	Nenhuma ação deferida.
PB	**03**	01	01	01	12	Suspensão de TODAS as Concorrências.
PE	**03**	01	01	01	18	Suspensão de TODAS as Concorrências.

PI	**01**	01	00	00	08	Suspensão da assinatura de TODOS os contratos até julgamento final do MS.
PR	**01**	01	00	00	82	Suspensão de TODAS as Concorrências.
RJ	**31**	03	11	17	60	Suspensão de 03 Concorrências.
RN	**02**	00	02	00	12	Nenhuma ação deferida.
RO	**00**	-	-	-	08	Não houve ação judicial.
RS	**17**	01	10	06	86	Suspensão de TODAS as Concorrências.
SC	**13**	03	05	04	24	Suspensão de TODAS as Concorrências.
SE	**01**	01	00	00	09	Suspensão de TODAS as Concorrências
SP	**80**	37	08	35	301	Suspensão de TODAS as Concorrências.
SPI	**01**	01	00	00	123	Suspensão de TODAS as Concorrências
TOTAL	**229**	**67**	**79**	**80**	**941**	**Suspensão de 720 Concorrências.**

• 76,51 % DAS CONCORRÊNCIAS ESTÃO SUSPENSAS, EM VIRTUDE DAS LIMINARES DEFERIDAS.

Por certo haverá mais algumas milhares de ações propostas por aqueles que perderem esta licitação acusando que a mesma esta fundada em um Decreto Inconstitucional, o que provocaria um caus jurídico maior do que foi implantado atualmente, prejudicando não apenas o franqueado e a ECT, mas principalmente o serviço postal e os cofres públicos.

Quando se tem por objetivo comprovar a constitucionalidade das regras contidas na Lei 11.668/2008, através de cautelar, não se tem apenas o objetivo de favorecer ao interesse pessoal dos associados, pois trata-se de assunto de interesse coletivo que atinge a todos os franqueados, bem como atinge a sociedade, além de proteger os próprios interesses da Administração Pública, da própria ECT, que não teria que acionar nenhum plano de contingência.

Noutro vértice, ao afastar a legitimidade de uma associação, sem antes verificar a profundidade e relevância do tema que a mesma visa defender é o mesmo que violar as regras insculpidas no art. 5°,

inc. XVII e XVIII, bem como a regra contida no art. 174 §2° de nossa Constituição Federal.

Assim define a regra contida no art. 174 §2° da Constituição Federal:

> ***"§2° - A Lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo".***

Por analogia é possível firmar entendimento no sentido de que tal regra não visa apenas o desenvolvimento econômico de uma associação, mas estrutural, social, e se assim o é, por certo não lhe possibilita mediante todas as dificuldades que existem para que se forme uma associação, que esta venha emergir sem incentivos e estímulos.

O que ocorre quando de pronto se julga extinta uma ADC sem julgamento do mérito sob a razão de que a associação não esta representada em nove estados da Federação, permitindo que tal fato seja tratado como requisito legal para propositura de uma ação de interesse nacional, é o mesmo que desestimular e deixar de incentivar confrontando assim a regra supracitada.

Não obstante, se é **plena** a **liberdade** de uma associação para fins lícitos e a criação destas não podem sofrer interferência estatal em seu funcionamento conforme reza a regra contida nos incisos XVII e XVIII do art. 5° de nossa Carta Magna, quando se restringe o alcance de sua legitimidade por conta de uma "representatividade", o que se faz na verdade é ferir a liberdade plena e ainda provocar a interferência do Estado, enquanto poder máximo judiciário – STF no funcionamento e regulamento de cada associação.

Vale aqui lembrar que tal regra foi idealizada a partir de um modelo de regulamento referente aos partidos políticos, de forma análoga e a partir de então foi generalizada, aplicando-se a toda e qualquer associação independente do propósito e alcance do objeto da ação.

Em tese ao se deparar com a violação das regras supracitadas, também tem-se que o **principio do devido processo legal** foi maculado pois sobretudo se está compelindo o direito à justiça, o direito de ação.

Importante ainda com fulcro na regra do **art. 5°, inc. LIV da Constituição Federal**, que ao determinar que uma associação não tem

legitimidade para determinada e única ação, é tratar com iniqüidade tal questão, e, desta forma estaria se ferindo outro principio, o principio da isonomia, da igualdade.

Neste sentido, ou uma associação de caráter nacional tem legitimidade para propor as ações que lhes determina a legislação, pois formada para defender interesses de seus associados em âmbito nacional ou não tem legitimidade alguma.

A própria regra contida no art. 103, inciso IX da Constituição Federal foi devidamente regulamentada pela Lei 9.868/1999, que por sua vez, conforme definiu a EC-45/2004 passou a considerar como legítimos para a propositura de uma ADC, os mesmos proponentes legitimados para a propositura de uma ADI.

Daí o risco de se presumir analogamente que a regra prevista na lei orgânica dos partidos políticos possa ser base para todas as demais associações existentes em nosso país.

Via de regra, a lei orgânica estabelece a representatividade em nove ou mais Estados Federados do país para partidos políticos como forma de legitimá-los como partido político e não para proporem Ação judicial.

Não obstante, a própria lei orgânica dos partidos políticos assegura na regra contida no artigo 3° da Lei 9.096/1995 sua plena liberdade como preceito fundamental contido na Constituição.

Trata-se o presente objeto jurídico tutelado de interesse coletivo num primeiro momento, um direito coletivo que não apenas pode assistir a classe à qual esta associação esta vinculada mas também atinge a terceiros que ainda não são franquias de correio, ficando assim vinculado até mesmo a um **interesse difuso**.

Conforme definição do ilustre Ministro, ex-presidente do STF, Gilmar Ferreira Mendes em sua obra acerca do tema, tem-se que:

> *"Relativamente à legitimidade das "entidades de classe de âmbito nacional" e das "confederações sindicais**", é difícil admitir a juridicidade da exigência quanto à representação da entidade em pelo menos nove Estados da Federação**, como resultado decorrente da aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos".*

> *Ainda que se possa reclamar a fixação de um critério preciso sobre tais conceitos vagos – entidade de classe de âmbito nacional e confederação sindical -,* ***não há duvida de que eles devem ser fixados pelo legislador e não pelo Tribunal****, no exercício de sua atividade jurisdicional. O* ***recurso à analogia*** *aqui é de* ***duvidosa exatidão****".(ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, EDITORA SARAIVA, 2009 1 EDIÇÃO, MENDES, GILMAR FERREIRA, PG. 99).Grifo Nosso.*

Desta forma, **data máxima vênia**, o peso que tem a decisão desta Excelsa Corte como norte para o desenrolar dos embates jurídicos, estas decisões não podem e não devem suplantar preceitos fundamentais, não apenas tocantes a legitimidade como ora se aborda, mas também em razão dos preceitos fundamentais que se pretende violar em decorrências das ações em trâmite.

Por outro lado, inadvertido seria determinar a ilegitimidade de uma associação de caráter nacional em face de uma determinada "representatividade física", como se esta representatividade não fosse mutável, como se à esta associação no curso do processo não pudessem se afiliar outros franqueados de todo o país.

O tratamento que se tem dado ao presente tema deve ser revisto, para assim, poder a presente ADC ser analisada e os preceitos fundamentais aqui ditos passiveis de violação serem defendidos por esta Excela Corte como bem opinou os eminentes juristas Celso Ribeiro bastos e Aléxis Galiás de Souza Vargas, quando do julgamento da ADPF:

> *"(...) Com isso, o Excelso Pretório cumpre o seu papel primordial de guardião-mor da Constituição e da ordem jurídica, bem como faz uma ponte entre o controle concentrado e o difuso, uma vez que sua decisão incidirá diretamente sobre os diversos processos judiciais...". Há que se decidir univocamente sobre o tema magno, sob pena de ser atropelada a segurança jurídica e o Estado de Direito, que ficam seriamente prejudicados diante do dissenso acerca dos seus pilares de sustentação, que são os preceitos fundamentais da Lei Maior".*(PRECEITO FUNDAMENTAL E A AVOCATÓRIA, *IN*

SUPLEMENTO DIREITO E JUSTIÇA DO JORNAL CORREIO BRASILIENSE DE 26.06.2000).

Com todo o respeito, faço das palavras dos eméritos juristas, supracitados, minhas palavras para concordar e dizer que se cabe ao Excelso Pretório o papel de guardião-mor da Constituição, necessário que nenhuma presunção análoga, como esta que ora se discute, exceda aos preceitos fundamentais, dos quais o Supremo Tribunal Federal, deve firmá-los contra a imperícia jurídica do ato normativo que origina a inconstitucionalidade, bem como, poder declarar uma Lei como sendo constitucional.

Trata-se portanto a presente associação de verdadeira entidade de classe, que visa defender e representar os interesses inerentes à atividade desenvolvida por seus associados, qual seja, a de franquia postal.

I – d) DA CONTROVÉRSIA EXISTENTE ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.668/2008

Outro fator importante é a existência de discussões judiciais, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, acerca da inconstitucionalidade da Lei 11.668/2008, que possibilite o processamento da ADC, como ação pacificadora e unificadora.

Desta forma, necessário citar algumas, das inúmeras ações em trâmite que discutem a inconstitucionalidade da Lei 11.668/2008 e/ou indiretamente discutem a licitação fundamentada no Decreto 6.639/2008, conforme abaixo descrito:

- ADI 4155 – STF;
- Rcl 10177 – STF;
- 5008530-56.2010.404.7000–JF-PR;
- 0002595-40.2010.401.3400–JF–DF;
- 5001212-22.2010.404.7000
- 5001327-43.2010.404.7000
- 5001442-64.2010.404.7000
- 5001981-30.2010.404.7000
- 5002121-64.2010.404.7000
- 5002549-46.2010.404.7000
- 5002553-83.2010.404.7000

√ - 5002796-27.2010.404.7000
√ - 5002938-31.2010.404.7000
√ - 5003570-57.2010.404.7000
√ - 5004912-06.2010.404.7000
√ - 5005468-08.2010.404.7000
√ - 5005568-60.2010.404.7000
√ - 5010256-65.2010.404.7000
√ - 5010613-45.2010.404.7000

Acima, citou-se algumas das principais demandas judiciais que discutem a inconstitucionalidade/constitucionalidade da Lei 11.668/2008, oportunizando assim na esteira da Ação Declaratória de Constitucionalidade a discussão que ora se apresenta.

Por certo que a maior relevância, no que tange a controvérsia judicial, está contida na **ADI 4155**, que impugna as regras contidas nos artigos 7° §único e 10° da Lei 11.668/2008.

Todavia, também é de grande relevância o tema, objeto da presente ADC, já que a determinação da constitucionalidade desta lei, evita prejuízos e violações não apenas ao direito que assiste aos franqueados, mas principalmente ao direito do cidadão em face de um serviço público essencial.

II) DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS

A presente ADC – Ação Declaratória de Constitucionalidade tem por objetivo demonstrar a Constitucionalidade das regras contidas na Lei 11.668/2008, para tanto, necessário uma retrospectiva dos fatos até o presente momento, cuja finalidade é o esclarecimento de como nasceu esta relação jurídica, seu desenvolvimento e manutenção, até a promulgação da Lei de Franquia Postal.

A criação do sistema de franquia postal teve origem no Brasil no ano de 1990 e tinha por necessidade e objetivo:

√ - expandir sua rede de atendimento em decorrência do aumento da demanda e crescimento deste tipo de serviço no país;

√ - expandir, suprindo desta forma a falta de recursos próprios à época para inaugurar pontos próprios;

√ - garantir assim a eficiência do serviço postal, afastando à época vários concorrentes e empresas multinacionais interessadas neste tipo de prestação de serviço, garantindo o monopólio da requerida.

Primeiramente, foram criadas as ACS – Agencia de Correio Satélite e logo em seguida foram autorizadas a contratação das ACF – Agencia de Correio Franqueada, em substituição àquela.

A presente relação jurídica firmada há mais de 17 anos, entre os associados – ACF – Agencia de Correio Franqueado e a ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, consagra-se através do preceito fundamental insculpido na regra rígida constitucional, qual seja, artigo 5° inc. XXXVI.

Presente também na regra contida na Lei de Introdução ao Código Civil em seu artigo art. 6°, §1° e § 2°.

O atual contrato de franquia firmado entre as partes tem por fundamento jurídico a Lei 6.538/1978, art. 2°, §3°, à qual dispõe sobre serviços postais e permite que a empresa exploradora de tais serviços possa celebrar contratos e convênios.

Todavia, com a necessidade de se regularizar os contratos administrativos, bem como, determinar sua natureza e peculiaridades, visto a presença inegável em nossa Carta Magna da regra contida no artigo 37, inc. XXI e do artigo 175, também o legislador entendeu por bem regularizar os contratos de franquia postal.

Importante antes de passarmos a discutir a regularização dos contratos de franquia postal, entendermos que a Lei 8.666/1993 regulamenta o art. 37, inc. XXI e a Lei 9.074/1995 regulamenta o art. 175, que fala sobre as concessões e permissões nos contratos de prestação de serviços públicos.

Superada esta questão, passemos a analisar os fatos a partir do momento em que a Lei de Franquia Postal foi criada, Lei 11.668/2008.

O legislador conforme determinava a Lei 9.648/1998, artigo 3°, inc. VII, Parágrafo único, acrescido à Lei 9.074/1995 no §1° do art. 1°, deveria regularizar os atuais contratos de franquia até o prazo de 31 de dezembro de 2002, prazo este que foi renovado com medidas provisórias, até o advento da Lei que visava regularizá-los (Lei 11.668/2008).

Assim determinava o parágrafo primeiro do artigo 1° da Lei 9.074/1995:

"VII – os serviços postais.

Parágrafo Primeiro. Os atuais contratos de exploração de serviços postais celebrados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT com as Agencias de Correio Franqueadas – ACF, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão à delegação das concessões ou permissões que ***os substituirão****, prazo esse que não poderá ser inferior a de 31 de dezembro de 2001 e não poderá exceder a data limite de 31 de dezembro de 2002".*

Mais adiante será possível verificar que a Lei 11.668/2008 revogou este parágrafo pelo simples motivo de que não tinha nenhuma pretensão em substituir o contrato atual de franquia por contratos provenientes de concessão e/ou permissão, mas sim, tinha o objetivo de manter e expandir os atuais contratos, regularizando-os, art. 6°, inc. III da própria Lei 11.668/2008.

Depara-se assim com a Lei 11.668/2008 que fica **vinculada diretamente** a mesma Lei que vincula os atuais contratos de franquia postal, qual seja, a Lei 6.538/1978 (art. 1°§1° da Lei 11.668/2008), bem como fica **vinculada indiretamente**, ou seja, subsidiariamente às Leis 10.406/2002; 8.955/1994 e 8.666/1993, sendo esta última a Lei que regulamenta o art. 37, inc. XXI da Constituição Federal.

A Lei 11.668/2008, respeitando a atual relação jurídica, que ora vige, previu que esta relação jurídica proveniente do ato jurídico perfeito de mais de 17 anos fosse **regularizada**, bem como, fosse **mantida**, como determinado expressamente no art. 6°, inc. III, que assim reza:

"Art. 6° - São objetivos da Contratação de Franquia Postal:

I - ...

II - ...

III – a ***manutenção*** *e* ***expansão*** *da* ***rede*** *de* ***Agencias dos Correios Franqueadas****, respeitando-se os princípios da*

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência";

Evidente até o momento que a Lei 11.668/2008 tinha o objetivo de regularizar os atuais contratos de franquia, sem criar um novo modelo, bem como, por estar vinculada indiretamente a Lei 8.666/1993, por se tratar de contrato de natureza especifica e com conteúdo próprio, o que o torna especifico, em momento algum foi igualado ao contrato de prestação de serviços públicos.

Fato é que não ficou vinculado, direta e/ou indiretamente, nem a Lei 9.074/1995, nem a Lei 9.648/1998 que regulam a regra contida no art. 175 da Constituição Federal.

Portanto a Lei 11.668/2008 é constitucional, contempla a atual relação jurídica, pois entende que a mesma apenas deva ser substituída posteriormente a regularização dos contratos vigentes, fato este que não ocorreu até a presente data, em decorrência do Decreto 6.639/2008 que é **inconstitucional** e da interpretação equivocada da ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sendo omissa acerca da violação de preceitos fundamentais contidas no Decreto 6.639/2008, e aplicando erroneamente a licitação na modalidade concorrência.

Visto por este ângulo, é possível firmar que a presente relação jurídica deve **continuar vigente** até que regularizada, bem como não pode ser substituída por outro modelo – AGF -, como proposto pelo Decreto, conforme determina o próprio art. 7° da Lei 11.668/2008, ou seja:

"*Art. 7° - Até que **entrem em vigor** os contratos de franquia postal celebrados **de acordo** com o estabelecido nesta Lei, **continuarão com eficácia** aqueles firmados com as Agencias de Correios Franqueadas que estiverem em vigor em 27 de novembro de 2007*".

Doutra sorte, no passo em que a presente relação jurídica seguia o norte correto, veio o Decreto 6.639/2008 e atropelou os preceitos fundamentais de nossa Carta Magna como o **princípio da legalidade**, o **principio da igualdade**, **o ato jurídico perfeito** e **o direito adquirido**, bem como, **principio à livre iniciativa** e o **livre exercício do trabalho**.

Atropelou, pois extrapolou o poder regulamentador do ato normativo criando um novo modelo de franquia (AGF) sem qualquer

estudo de viabilidade econômico financeira, bem como, sem qualquer previsão legal.

Ainda, em decorrência de ter criado um novo modelo determinou a rescisão do atual contrato de franquia, a extinção da atividade de franquia postal (ACF), determinando um prazo para que esta relação jurídica, hoje vigente, terminasse.

Por tais motivos é que os associados discutem em ações individuais as irregularidades do edital de licitação, bem como sua inexigibilidade.

Por tais motivos é que esta Associação ingressou com a **ADI 4437** junto ao STF, reivindicando a **inconstitucionalidade** do artigo 2° §3° inc. I, artigo 4°, artigo 5° e artigo 9° §§ 1° e 2° do Decreto 6.639/2008.

Tais decisões não apenas afrontam a segurança jurídica, como também a própria Lei 11.668/2008, como se tornam decisões abusivas que extrapolam o poder discricionário que cabe a Administração Pública em alguns casos.

Não obstante, quando a ECT passa a vincular nos mais variados veículos de comunicação a existência de planos de contingência, contratações sem licitações, contratações emergenciais com voluptuosos custos para a própria Estatal – ECT, sob a denuncia de um possível apagão postal, não apenas coloca em risco a própria Administração Pública, mas principalmente terceiros que dependem deste serviço e os próprios franqueados.

A Lei 11.668/2008, em momento algum propiciou à Administração Pública, que esta, infringisse dois princípios máximos e gerais dos contratos, ao qual se submete o atual contrato de franquia, ainda pendente de regularização, ou seja:

> ***"Principio da Obrigatoriedade**: Pelo principio da obrigatoriedade (pacta sun servanda), deve-se assegurar o cumprimento do contrato, em todos os seus termos, vinculando-se os negociantes para esse fim.*
>
> *Surge daí a idéia de que o contrato é "lei entre partes", uma vez que elas não podem se escusar a seu*

*cumprimento". (*CONTRATOS - LISBOA, ROBERTO SENISE – ED. SARAIVA – 4 EDIÇÃO – PG. 41).

"***Principio da Intangibilidade****: Uma vez celebrado o ajuste, busca-se sua manutenção a fim de que os contratantes possam satisfazer os seus interesses (necessidades).*

*O principio da conservação do contrato, denominado principio da intangibilidade ou imutabilidade, impossibilita, via de regra, a mutação do conteúdo do negócio jurídico, para a preservação dos interesses dos pactuantes". (*CONTRATOS - LISBOA, ROBERTO SENISE – ED. SARAIVA – 4 EDIÇÃO – PG. 43).

Mesmo sob o peso de tratar-se de contrato administrativo, a idéia de poder discricionário não é tão abrangente e autorizadora a ponto de interferir no equilíbrio de uma relação jurídica sem qualquer justificativa.

Marçal Justen Filho em sua obra acerca do tema assim tem se posicionado:

"*A alteração do contrato retrata, sob alguns ângulos, uma competência discricionária da Administração. Não existe, porém, uma liberdade para a Administração impor a alteração quando e como melhor lhe aprouver. Tal como anotado no comentário ao art. 58, ao qual se remete, a contratação é antecedida de um procedimento destinado a apurar a forma mais adequada de atendimento aos interesses fundamentais. A Administração, após realizar a contratação, não pode impor alteração da avença mercê da simples invocação da sua competência discricionária".* (COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 14 ED. EDITORA DIALÉTICA, FILHO, MARÇAL JUSTEN, PG. 771)

Assim determina a súmula 473 do Pretório Excelso:

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam

> ***ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.***

Desta forma, a presente relação jurídica, ainda vigente não pode sofrer qualquer tipo de alteração econômico-financeira, bem como, não pode ser extinta sem antes ter sido cumprido o que determina a Lei 11.668/2008, devendo tais contratos serem mantidos até que os mesmos sejam regularizados o que está distante de ocorrer com mais de 76% das licitações suspensas e com a propositura da **ADI 4437** junto ao STF.

III) DO TEXTO DA LEI 11.668/2008 QUE SE DECLARA CONSTITUCIONAL

A seguir fica exposto o texto que se pretende declarar constitucional, considerando que os mesmos atuam e tecem normas conforme os ditames de nossa Carta Magna e demais legislações vigentes.

> *"Art. 6° – São objetivos da contratação da franquia postal:*
>
> *III – **a manutenção e expansão** da rede de Agencia dos Correios Franqueadas, respeitando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e;*
>
> *IV – a melhoria do atendimento prestado à população".*
>
> "*Art. 7° - Até que **entrem em vigor** os contratos de franquia postal celebrados **de acordo** com o estabelecido nesta Lei, **continuarão com eficácia** aqueles firmados com as Agencias de Correios Franqueadas que estiverem em vigor em 27 de novembro de 2007*".

Os artigos supramencionados são constitucionais, porque asseguram o **direito adquirido**, o **ato jurídico perfeito**, o **principio da legalidade**, **da igualdade**, **da livre iniciativa e do livre exercício do trabalho**, todos preceitos fundamentais contidos em nossa Carta Magna.

"Art. 10° - Fica revogado o §1° do art. 1° da Lei n.° 9.074/1995, de 07 de julho de 1995".

Já a regra contida no artigo 10° garante que o **principio da legalidade** não seja violado, respeita a **coisa julgada**, pois admite em decorrência da congruência das decisões emanadas deste Pretório Excelso – ADPF 46, do Superior Tribunal de Justiça - REsp 403.799-MG; REsp 873.440-RS; 953.840-RJ e do próprio TCU – Tribunal de Contas da União – AC 59/1998 e 1.695/2010, que o contrato de franquia postal, não se equipara a contratos de prestação de serviços provenientes da concessão e /ou permissão.

Adiante se faz uma breve análise acerca das decisões supramencionadas, que demonstram a coerência jurídica e constitucionalidade da Lei 11.668/2008, principalmente acerca de julgados históricos que desenharam o contrato de franquia postal, regido hoje pela Lei de Franquia Postal.

III – a) BREVE ANÁLISE ACERCA DAS DECISÕES QUE DEFINEM UM CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL QUANTO A SUA NATUREZA E OBJETO

Façamos uma breve análise sobre as decisões acerca dos contratos de franquia e/ou franquia postal, sua natureza e o que é de fato o serviço publico postal, conforme entendimento do STF, STJ e TCU, conforme abaixo relato:

O que se pretende fazer é uma licitação na modalidade concorrência em face de um novo modelo AGF, criado pelo Decreto 6.639/2008, **alvo da ADI 4437**, que por sua vez manda extinguir um ato jurídico perfeito, o qual a Lei 11.668/2008 determinou que fosse regularizado e mantido, art. 6°, inc. III e IV e art. 7°.

Portanto passarei a citar alguns pontos importantes que destacam a necessidade de descartar a idéia de que os contratos de franquia

postal estão submetidos à regra do art. 175 da Constituição Federal, conforme abaixo exposto:

> • O art. 37, inciso XXI da Constituição determina que ocorra licitação **exceto** nos casos específicos de nossa legislação.
>
> • A Lei 8.666/1993 (Lei de Licitações) é a lei que regulamente tal norma constitucional, e a exceção prevista no art. supracitado, encontra-se vinculada à regra contida no art. 116 desta Lei.
>
> • A Lei 11.668/2008 está vinculada de forma direta à Lei 6.538/1978 e **subsidiada** às Leis 10.406/2002 (Código Civil); Lei 8.955/1994 (Lei do Franchising) e Lei 8.666/1993 (Lei de Licitações).
>
> • A Lei 11.668/2008 deve utilizar como critério de julgamento o inciso IV do art. 15 da Lei 8.987/1995, **não estando subsidiada a tal legislação**.

Neste sentido, por qual motivo a Lei 11.668/2008 ficou vinculada tão somente a regra contida no art. 37, inc. XXI da Constituição Federal, já que não está subsidiada à Lei 9.074/1995 e a Lei 9.648/1998?

A resposta é clara e decorre de decisões que em processos e julgamentos históricos deram ênfase final ao presente tema, bem como a presente relação jurídica, ou seja:

A **ADPF 46** assim definiu através do voto do Ministro Carlos Britto:

> *"A constituição diz que **são atividades próprias da União**, típicas da União, encarregada a União de mantê-las, a caracterizar, portanto, uma compulsoriedade de prestação. Além de ser um serviço público, típico da*

União, não pode deixar de ser prestado, daí a Constituição fazer uso do verbo "manter".

A compulsoriedade da prestação do serviço me parece um elemento do respectivo regime jurídico. Além dessa titularidade pública Federal, ***parece-me não ser passível de transpasse para a iniciativa privada****, mediante os conhecidos institutos da autorização,* ***da concessão ou da permissão****, vale dizer até – não estou sendo exagerado assim ao asseverar –* ***que é o único serviço público não passível de transpasse para a iniciativa privada****, mediante os citados institutos. É uma atividade insusceptível de exercício privado. Logo tanto a titularidade, quanto a protagonização da atividade ficam no âmbito do setor público federal".*

Não é por menos que as franquias postais executam atividades auxiliares e não serviços públicos, não é por menos que o artigo 10° da Lei 11.668/2008, o qual se declara constitucional, revoga o §1° do art. 1° da Lei 9.074/1995.

Ainda: As decisões contidas nos REsp 403.799-MG; REsp 873.440-RS; 953.840-RJ, dentre outras junto ao Superior Tribunal de Justiça assim definem:

"A mera inserção da operação de franquia no rol de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 ***não possui o condão de transmudar a natureza jurídica complexa do instituto, composto por um plexo indissociável de obrigações de dar****, de fazer e de não fazer. Destarte,* ***revela-se inarredável que a operação de franquia não constitui prestação de serviço (obrigação de fazer)****, escapando, portanto, da esfera da tributação do ISS pelos municípios.*

Em termos mais rigorosos, todas características definitórias do definiendum "serviço" estão postas na

Constituição Federal. A lei complementar somente pode acrescer características ***acidentais ou acessórias****. Mas* ***não pode estabelecer, como serviço, o que não o é****. Por conseqüência, qualquer grandeza eleita para figurar na base de cálculo do ISS que não se origine das características definitórias constitucionais de "serviço" encontra-se* ***estigmatizada pelo vício da inconstitucionalidade."*** *(in obra citada, Organização de Heleno Taveira Tôrres, 1ª Ed., Ed. Manole, São Paulo, 2004, págs.236/237).*

(...) O contrato de franquia envolve cessão de marca, transferência de tecnologia, assistência técnica. ***É um conjunto de fatores e não prestação de serviços****. Esta, quando existente, é indissociável dos outros fatores. O franqueado não presta serviços ao franqueador ou vice-versa.* ***Franquia não é serviço****. É cessão de direitos. A supervisão de rede, orientação, treinamento do franqueado e de seus funcionários, escolha de ponto é* ***obrigação de meio*** *para a realização da franquia e não serviço.* ***A lei tributária não pode estabelecer um conceito diverso do previsto no Direito Comercial (art. 110, do CTN) para alterar a definição do instituto e considerá-lo como serviço, que não é.*** *(...) A franquia é um contrato complexo. Não é exatamente serviço. (...)" (In obra citada, 7ª ed., Ed. Atlas, São Paulo, 2006, págs. 272/278)".*

*FRANCHISING -NÃO INCIDÊNCIA DE ISS - PRECEDENTES. "****O contrato de franquia não se confunde com nenhum outro contrato****, porquanto possui delineamentos próprios que lhe concederam* ***autonomia****. Ainda que híbrido, não pode ser configurado como a fusão de vários contratos específicos" (voto-vista*

proferido por este signatário no julgamento do REsp 189.225/RJ, in DJ de 03.06.2002).";

"1. É pacífico no STJ que os serviços prestados por ***empresas franqueadas que realizam atividades postais e telemáticas não são tributados pelo ISS****. Precedentes (RESP 403.799-MG, DJ de 26.04.2004, Rel. Min. Franciulli Netto; RESP 189.225-RJ, DJ de 03.06.2002, Rel. Min. Peçanha Martins; AGA 436.886-MG, DJ de 28.10.2002, Rel. Min. Garcia Vieira).*

2. Entretanto, in casu, impõe-se a ***aferição da natureza do contrato, em face da sua atipicidade****. Nessas hipóteses a C. 1ª Turma externou entendimento segundo o qual 'A verificação da natureza dos contratos celebrados pela EBCT e as agências de correios (se franquia empresarial, representação comercial ou agenciamento) para efeitos de incidência do ISS, enseja a análise apurada de suas cláusulas, providência inviável no âmbito do recurso especial, conforme dispõe a Súmula 05/STJ.' (AGRESP 442.225-PR, DJ de 30.08.2004, Rel. Min. Teori Zavascki)".*

"...seja antes ou após a LC 116/03, não há falar em inexistência de relação jurídica tributária, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos da inicial era medida que se impunha", o juízo monocrático, com ampla cognição fático probatória, asserindo a natureza de franquia relativa ao contrato em tela, assim se manifestou, in verbis: ***"Cotejando, assim, a definição legal da espécie contratual e aquilo que de fato contrataram as partes, não há como negar que realmente se está diante de pacto de franquia empresarial****, porquanto presentes, na definição, todos os requisitos a tanto legalmente instituídos.(...) Como ressaltado, a definição do objeto e das tarefas*

> ***contratuais dão conta de que a franqueada exerceria as atividades sob a marca dos correios, formalizando ACF (agência de correio franqueada)**, e distribuindo, em nome próprio, os serviços **prestados originalmente por aquele**, cobrando as respectivas tarifas e repassando ao franqueador a remuneração ajustada pela cessão da marca. Não me parece, portanto, que a atividade descrita se enquadre na definição do art. 1º da Lei 4.886/65".*

Os textos supramencionados refletem bem o entendimento acerca da impossibilidade de se alterar a natureza do contrato de franquia postal, mesmo que a Lei pretenda fazê-lo, o que não ocorre com a Lei 11.668/2008, já que esta não submeteu o contrato à regra do art. 175 da Constituição Federal, logo não submeteu o contrato as Leis que regulam a prestação de serviços públicos provenientes da concessão e/ou permissão.

Ainda, importante que o Pretório Excelso veja o que entende o próprio TCU acerca da **subsidiariedade** do contrato de franquia postal às Leis e à sua natureza, conforme acórdão 59/1998 e 1.695/2010, voto do relator:

> *"8. De outra parte, embora seja patente a necessidade de realização de licitação pública para a celebração dos contratos de franquia, por força de disposição constitucional (**arts 37, inc. XXI**, e art. 175), e como há tempos vem defendendo este tribunal (v.g. Decisão 601/1994 – TCU – Plenário), é certo também que essa contratação **não se subsume integralmente às disposições da Lei n. 8.666/1993**, até porque esta lei **aplica-se subsidiariamente aos contratos da espécie**, conforme estabelece o art. 3 da Lei de regência.*
>
> *9. Assim, conceitos e procedimentos próprios da Lei de Licitações **não podem ser transpostos e aplicados indistintamente aos contratos da espécie**, devendo-se,*

*antes de tudo, **atentar-se para a natureza jurídica peculiar aos contratos de franquia**, instituto eminente de direito privado, consoante depreende-se do conceito de franquia trazido pela Lei 8.955/1994.*

10.... III – AC 59/98

*17. A atenta leitura da doutrina especializada demonstra de forma clara que as franquias estão a construir **modalidade própria de contrato**, atípico, posto não dispor de regulamentação específica, mas que possuí características específicas que **as distinguem das demais espécies contratuais**, **não há que se confundir o contrato de franquia empresarial com outras modalidades de negócios jurídicos**, **em especial o contrato de concessão de serviço público"**.*

Atenta-se aqui ao fato de que o próprio TCU entende que a natureza do contrato de franquia é própria e não se confunde com a prestação de serviços públicos, bem como, a Lei 11.668/2008 está subsidiada apenas a Lei 8.666/1993, ou seja, ao art. 37 inc. XXI da Constituição e mesmo assim deve ser respeitado o instituto.

Pergunta-se, como então é possível determinar que a licitação da forma como realizada está correta?

Temos assim, de forma objetiva e coerente, decisões do STJ, STF e do TCU que indicam que o contrato de franquia postal **não pode ter sua natureza jurídica modificada**, que o contrato de franquia **não se confunde com o contrato de prestação de serviços públicos**, que a Lei de Franquia postal de fato **está subsidiada a Lei 8.666/1993**, portanto está **submetida à exceção da regra contida no art. 37, inciso XXI** da Constituição Federal, que o contrato de franquia **não se equipara às concessões e permissões**, ou seja, prestação de serviços públicos (art. 175), que o serviço público postal **não pode ser transpassado para o setor privado**, logo **não pode ser transpassado para franquias**, que exercem atividades auxiliares, portanto não se trata de licitação na

modalidade concorrência como se tratasse de prestação de serviço público decorrente de uma concessão, mas sim de contratação direta.

Não se trata de prestação de serviços públicos, mas sim de atividade auxiliar desenvolvida pelas franquias, portanto trata-se de contrato administrativo de franquia postal, cuja obrigatoriedade de formalização do ato decorre da exceção prevista na Lei 8.666/1993, todavia, em momento algum se torna um ato inconstitucional ou que vise à perpetuação de alguém frente ao negócio.

IV) DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

Tal pretensão tem como fundamento jurídico a regra contida no art. 5° inc. XIII, XXXV e XXXVI; art. 8°; art. 37 inc. XXI; art. 102 inc. I a); 103 inc. IX da Constituição Federal, art. 273 §7° do Código de Processo Civil, Lei 9.868/1999 e demais legislações pertinentes ao caso visto em tela.

V) DO PEDIDO CAUTELAR CONFORME REGRA PREVISTA NO ARTIGO 21° E SEGUINTES DA LEI 9.868/1999

Passa-se a expor os fundamentos que demonstram a necessidade do deferimento da medida cautelar, cujo objetivo é afastar o perigo iminente que sofre os franqueados em face da fumaça do bom direito e do perigo da demora que ora se apresenta.

Necessário, portanto que se demonstre e verifique a necessidade da medida de urgência no sentido de fazer prevalecer o entendimento de que a Lei 11.668/2008 é constitucional, principalmente os artigos 6°, 7° e 10°.

Em citação ao mestre Marinoni, o Prof. Antonio Claudio da Costa Machado assim se manifesta:

> *"Tem razão, portanto, Luiz Guilherme Marinoni quando assevera que, "a cognição sumária é uma cognição menos aprofundada em sentido vertical... própria das*

situações de aparência, ou melhor, dos juízos de probabilidade", arrematando, em seguida, que se trata, "da cognição pertinente aos procedimentos que não permitem, em razão de uma determinada situação, a cognição aprofundada do objeto litigioso" e que é "característica da tutela cautelar e da tutela sumária antecipatória".

Por conseguinte, como se trata de provar a constitucionalidade de tais regras, e com isso, preservar preceitos fundamentais, cuja interpretação e aplicação em nossa Carta Magna é rígida, também se faz necessário demonstrar que a interpretação equivocada desta Lei, em decorrência do ato normativo – Decreto 6.639/2008 – este sim violador de preceitos fundamentais, traz danos irreversíveis a todos, franqueado, ECT, e para a sociedade enquanto consumidora deste serviço essencial público.

Desta forma, num primeiro momento, como necessidade obrigatória de se manter um serviço público essencial, necessário que seja concedida medida cautelar cuja finalidade é a manutenção dos atuais contratos de franquia postal, até que estes sejam regularizados conforme a Lei 11.668/2008 determina.

- Considerando que a Lei 11.668/2008 **não determina a extinção** da atual rede de Agencia de Correios Franqueadas – art. 6° inc. III;
- Considerando que a Lei 11.668/2008 determina a **melhoria no atendimento prestado a população** - art. 6° inc. IV;
- Considerando que a Lei 11.668/2008 **não determina a extinção da atual relação jurídica**, mas sim sua regularização – art. 7°;
- Considerando que a Lei 11.668/2008 não determina que a atual rede de agencia de correios franqueadas **seja substituída** por outro modelo, neste caso AGF, conforme inovou o ato normativo – art. 6° III e art. 7°;
- Considerando que a Lei 11.668/2008 **não equiparou** o contrato de franquia postal aos

contratos de prestação de serviço público – concessão e/ou permissão – art. 10°;

Dentre as considerações acima citadas, destaca-se o fato de que em momento algum, a Administração Pública, ou seja, a ACT preocupou-se em cumprir com o que determina a regra contida no inciso IV do art. 6°, ou seja, melhorar o serviço prestado à população.

O que se tem visto é justamente o contrário, um serviço postal deteriorado e que por certo a ECT não teria condições de assumir todas as atividades auxiliares desenvolvidas pelos franqueados e, ainda, de forma irregular, caso as teses contidas na ADI 4437 e demais ações vençam.

Necessário, não apenas definir que os atuais contratos, ou seja, a atual relação jurídica deve ser mantida, até que seja de fato regularizada conforme a Lei 11.668/2008 determina, bem como, determinar que todas as ações em trâmite no país, que discutam a licitação fundamentado na Lei 11.668/2008 e no Decreto 6.639/2008 sejam suspensos, conforme determina a regra contida no art. 21 da Lei 9.868/1999.

Não conceder a medida de urgência, em meio a tantas discussões judiciais e em meio há mais de 70 % das licitações suspensas é provocar **contratações emergenciais equivocadas**, que demandarão um alto custo por parte da Administração Pública e **sem resolver o problema**.

Não conceder a medida de urgência, seria possibilitar que as franquias de todo o país sejam fechadas em data de 10 de novembro de 2010, conforme é o entendimento da ECT, já divulgado publicamente, entendimento este equivocado, já que o prazo de 24 meses para a regularização foi concedido à ECT regularizar os contratos e não como prazo final para a presente relação jurídica.

Não conceder a medida de urgência seria possibilitar que a ECT, ao realizar o fechamento destas mais de 1400 unidades, provocasse mais 1400 demandas judiciais, além de ter a obrigação de absorver atividade extras, das quais não tem como suportar, o que daí sim poderia provocar uma verdadeiro apagão postal.

Tem-se no presente processo judicial que visa auxiliar o controle da constitucionalidade, o objetivo de demonstrar que nada

disso precisa ocorrer se de fato a Lei 11.668/2008 for interpretada de forma correta.

Por tais motivos necessário que seja deferida a presente cautelar, com efeito *ex nunc*, conforme abaixo descrito:

- Seja determinado que os atuais contratos de franquia continuem vigentes, mesmo após a data de 10 de novembro de 2010, até que os mesmos sejam regularizados conforme determina a Lei 11.668/2008 e demais decisões judiciais como aquelas que definirão a inconstitucionalidade do Decreto 6.639/2008, cuja finalidade é evitar prejuízos e danos irreversíveis aos franqueados, a ECT e a terceiros, bem como, aos cofres públicos e a própria sociedade, afora a necessidade de garantir a segurança jurídica e o Estado de Direito, uma vez presentes o "*fumus boni juris*" comprovados através da verossimilhança das alegações e documentos juntados e o "*periculum in mora*";

- No mesmo sentido seja suspenso o julgamento em todas as ações judiciais em trâmite que estejam discutindo não apenas a constitucionalidade e/ou a inconstitucionalidade da Lei 11.668/2008, mas todas as demais ações judiciais que estejam discutindo os editais de licitação, pois esta licitação está fundada no Decreto 6.639/2008 que regulamenta a Lei 11.668/2008, ato normativo este, que em tese está sendo declarado inconstitucional através da ADI 4437.

A medida de urgência ora requerida, se faz necessária visto a presença da verossimilhança das alegações presentes nesta ADC, uma vez que, uma licitação não pode ocorrer quando decorre de um ato normativo inconstitucional – ADI 4437, que violou os princípios da legalidade, da livre iniciativa e do livre exercício do trabalho, todos preceitos fundamentais.

No mesmo diapasão não pode o prazo a que faz menção o parágrafo 2° do artigo 9° do Decreto 6.639/2008 continuar vigente, já que

fere o **ato jurídico perfeito**, o **direito adquirido** e ainda determina a data **final de uma relação jurídica**, todos preceitos fundamentais.

Tanto em um momento quanto em outro a presença de violação de preceitos fundamentais, possibilita que a presente cautelar, em sede de cognição sumária, seja alcançada, pois da simples análise superficial impossível **infirmar** que a licitação e a extinção dos contratos vigentes ocorre em meio a um ato normativo inconstitucional.

Ainda com o objetivo de evitar que o preceito não seja cumprido, requer, desde já, seja aplicado uma multa diária, a ser arbitrado Pelo Emérito Ministro, conforme previsto na regra do art. 461 do Código de Processo Civil, sob pena de também se considerar descumprimento de ordem judicial:

> ***Art. 461 – "Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz concederá a tutela específica da obrigação, ou se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado equivalente ao do adimplemento.***
>
> ***...§ 5º - Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requerimento de força policial".***

Necessário a manutenção dos atuais contratos de franquia, até que exaurido toda e qualquer discussão acerca da inconstitucionalidade do Decreto, da Constitucionalidade da Lei, sob pena de qualquer relação jurídica proveniente deste procedimento licitatório estar abrigado sob um ato normativo inconstitucional.

VI – DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI 11.668/2008 E DA ADJUDICAÇÃO DIRETA – CONTRATAÇÃO DIRETA COMO FORMA CORRETA DE SE LICITAR

A Lei 11.668/2008 esta **vinculada de forma direta** a regra contida no §3°, do art. 2°, da Lei 6.538/1978, que nada mais é do que a possibilidade de contratar através de contratos como o de franquia ou convênios atendendo as conveniências técnicas, ou seja:

> *"Art. 2º - O serviço postal e o serviço de telegrama são explorados pela União, através de empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações.*
>
> *§ 3º - A empresa exploradora dos serviços, atendendo a **conveniências técnicas** e econômicas, e sem prejuízo de suas atribuições e responsabilidades, **pode celebrar contratos e convênios objetivando assegurar a prestação dos serviços**, mediante autorização do Ministério das Comunicações".*

A Lei 11.668/2008 esta **vinculada de forma indireta** a outras leis, conforme determina a regra contida no art. 3°, que assim estabelece:

> Art. 3° - *"Os contratos de franquia postal celebrados pela ECT são regidos por esta Lei e, **subsidiariamente**, pelas leis n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e 8.666, de 21 de junho de 1993, utilizando-se o critério de julgamento previsto no inciso IV do caput do art. 15 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995".*

Quando uma lei esta subsidiada a outras, é porque esta lei esta orientada, **vinculada de forma indireta** a tais leis, portanto não se submetendo à sua atividade jurídica de forma plena.

Veja Eméritos Ministros, até o presente momento tem-se que a Lei 11.668/2008 é a lei que regula a atividade de franquia postal no país, todavia, a mesma lei esta fincada nos preceitos estabelecidos pela Lei 6.538/1978 e subsidiada à outras leis, quais sejam, Lei 10.406/2002; Lei 8.955/1994; Lei 8.666/1993.

Veja que ainda deve utilizar como **critério de julgamento** àquele previsto no **inciso IV** da regra contida no art. 15 da Lei 8.987/1995, qual seja, melhor proposta técnica com preço fixado no edital.

Por qual motivo, a lei determina que seja seguida a regra prevista no inciso IV do caput do art. 15 e não aquela do caput do art. 15 do inc. IV, porque conforme adiante ficará demonstrado e comprovado, o contrato de franquia, não se trata de contrato de prestação de serviço normal, corriqueiro, tampouco de contrato comercial, já que tem causa e conteúdo próprios, conforme assevera o nosso Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Atenta-se aqui ao fato que a Lei 11.668/2008 não manda licitar na modalidade concorrência, determina que se utilize o critério de julgamento contido no inciso IV do art. 15, até porque a Lei 8.987/1995 faz alusão à licitação de contratos de prestação de serviços em decorrência de **permissão e concessão**, o que não se aplica a um contrato de franquia, ou seja:

> *"Art. 1° - As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos".*

Ora, Eméritos Ministros, a própria legislação em vigor responde a nossa pergunta, ou seja, a Lei 9.648/1998 assim alterou a Lei 9.074/1995:

> *"VII – os serviços postais.*
>
> *Parágrafo único. Os atuais contratos de exploração de serviços postais celebrados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT com as Agencias de Correios Franqueadas – ACF, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações* ***que precederão à delegação das concessões ou permissões que os substituirão****, prazo esse que não poderá ser inferior a de 31 de dezembro de 2001 e não poderá exceder a data limite de 31 de dezembro de 2002".*

Incluiu os serviços postais, autorizando que tais serviços também poderiam ser contratados mediante concessão e/ou permissão, mas

em hipótese alguma fez-se entender que o contrato de franquia era um contrato fruto da permissão ou da concessão, não equivalendo-os.

Veja que a Lei 11.668/2008 revoga este parágrafo, ou seja, elimina a hipótese de que tais contratos seriam provenientes da concessão ou permissão, uma vez que sequer fica subsidiada à Lei 9.074/1995.

Noutro vértice, a Lei 11.668/2008, em momento algum determina que os contratos de franquia postal, sejam os antigos, sejam os novos, tenham que ser licitados na modalidade concorrência, tampouco determina a criação de uma nova denominação para este tipo de contrato, já que faz alusão a Agencia de Correio Franqueado, ou seja, as ACFs, em seu art. 7°.

Importante aqui esclarecer que o critério de julgamento pode ser utilizado tanto para a contratação direta, quanto para a contratação via licitação na modalidade concorrência, pois ambos exigem ato formal.

A prova irrefutável de que não se pretendia mudar a denominação dada às franquias, bem como, não se pretendia licitar na modalidade concorrência outro modelo de franquia, ou seja, AGF, é o conteúdo da regra do art. 6°, inc. III e IV que assim determina:

> *"III – a **manutenção** e expansão da rede de **Agencia dos Correios Franqueadas**, respeitando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e;*
>
> *IV – a **melhoria do atendimento prestado à população**".*

Veja Eméritos Ministros, que, se a pretensão é de se manter o que já existe, impossível que tais contratos sejam licitados da forma como propõe o Decreto, pois provenientes de uma relação jurídica nascida justamente da regra contida no §3°, do art. 2°, da Lei 6.538/1978, que trata de contratos vinculados a contratação direta, adjudicação direta e que não são provenientes de uma licitação antecedente.

Ainda, se visa à melhoria no atendimento à população, por certo que jamais permitiria que fosse aberto um certame sem a presença da regra contida no art. 27 da Lei 8.666/1993, qual seja, sem a presença da habilitação – qualificação técnica.

Por fim, na regra contida no art. 7°, verifica-se que o que se determina de fato era a regularização dos contratos até então vigentes, todavia, como visto acima, não seria plausível regulá-los via meio licitatório na modalidade concorrência, possibilitou-se a regularização via meio licitatório mediante contratação direta submetendo de forma indireta o contrato de franquia postal, contrato atípico, às regras de determinadas leis, dentre as quais a de licitação.

A aplicação subsidiária da Lei 8.666/1993, bem como, o critério de julgamento supracitado, à Lei 11.668/2008, nada mais é do que a aplicação do conceito de contratação direta, como ocorre nos casos de convênios, acordo ou outros tipos de contratos, contratos estes específicos, exclusivos, como o de franquia postal.

Assim entende o Ilustre mestre Wellington Pacheco Barros:

> *"O contrato administrativo, segundo o parágrafo único do art. 2° da lei 8.666/1993, é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares envolvendo um acordo de vontades para o fim de formação de vínculo com a estipulação de obrigações recíprocas. Pelo dispositivo legal, claramente se observa que o contrato administrativo se formaliza tendo a Administração Pública e os particulares como contratantes.*
>
> *Dessa forma,* ***não se aplica*** *a lei 8.666/1993 de forma vinculante e obrigatória aos contratos firmados entre a Administração e particulares, como os convênios, acordos, ajustes ou qualquer outra forma contratual.* ***A aplicação é meramente subsidiária****. Questão lógica é a de que não se aplica a estes contratos a licitação apenas o que for pertinente a parte contratual".* (LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ED. ATLAS, BARROS, WELLINGTON PACHECO, 2009, PG 268)

É tão evidente a condição de contratação direta que a lei determina para o contrato de franquia postal que apenas que se faça constar, obrigatoriamente, determinadas cláusulas e condições, constantes

do art. 4° da Lei 11.668/2008, que praticamente repetem as condições estabelecidas na regra do art. 55 da lei 8.666/1993.

Ainda conforme a regra contida no art. 116 da Lei 8.666/1993, tem-se que:

> *Art. 116. "Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e* ***outros instrumentos congêneres celebrados*** *por órgãos e entidades da Administração".*

Pois bem, Eméritos Ministros, logo no início a Lei 11.668/2008 assim define no §1°, do art. 1°:

> *"Sem prejuízo de suas atribuições, responsabilidades e da ampliação de sua rede própria, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT* ***poderá utilizar o instituto da franquia*** *de que trata o caput deste artigo para desempenhar* ***atividades auxiliares relativas ao serviço postal***, ***observado o disposto no §3° do art. 2° da Lei 6.538 de 22 de junho de 1978****".*

O §3° do art. 2° da Lei 6.538 de 22 de junho de 1978 assim determina:

> *"Art. 2º - O serviço postal e o serviço de telegrama são explorados pela União, através de empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações.*
>
> *§ 3º - A empresa exploradora dos serviços, atendendo a conveniências técnicas e econômicas, e sem prejuízo de suas atribuições e responsabilidades,* ***pode celebrar contratos e convênios objetivando assegurar a prestação dos serviços****, mediante autorização do Ministério das Comunicações".*

A celebração de contratos e convênios nada mais é do que a possibilidade da adjudicação direta nesta contratação, cuja mesma base orientou a contratação dos contratos atualmente em vigor e que trata-se de um ato formal vinculado o processo administrativo.

Portanto, o preceito constitucional ao qual esta submetido a presente relação jurídica não é o da regra contida no art. 175 da Constituição Federal, mas sim o da regra contida no artigo 37 inc. XXI da Constituição Federal.

Assim determina o art. 37, inciso XXI de nossa Carta Magna:

> *"XXI - **ressalvados os casos especificados na legislação**, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure **igualdade de condições** a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, **mantidas as condições efetivas da proposta**, **nos termos da lei**, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".*

O presente artigo, regulado pela Lei 8.666/1993, quando interpretado deixa evidente que existe logo no início a consideração as ressalvas que por ventura possam existir em nossa legislação, determinando ainda que a igualdade de condições seja respeitada e mantida as condições de acordo com a Lei.

No que pese, em tese, se defender que o contrato regido pela Lei 11.668/2008 esta submetido à regra contida no art. 37, inc. XXI, e não ao art. 175 da Constituição, o Decreto, ora impugnado, não respeita em momento algum o conteúdo que se exprime do inciso XXI supramencionado.

Ora, Excelsa Corte, o Decreto 6.639/2008 não respeita os termos da Lei 11.668/2008, alterando-a, criando uma nova modalidade, enquanto a Lei pretendia e objetivava a manutenção e expansão do modelo já existente, determina que haja licitação para este novo modelo e na modalidade concorrência, momento no qual jamais conseguiria chegar a condições de igualdade entre os atuais franqueados e terceiros interessados que não detém experiência alguma e por fim não trataram da Lei 11.668/2008 como um contrato administrativo, previsto como exceção, que é proveniente de uma legislação própria e que se enquadra na ressalva inicial do inciso citado.

Outrossim, passa-se a expor e impugnar as regras contidas no Decreto 6.639/2008, por serem inconstitucionais, bem como, por terem alterado e excedido os preceitos e regras contidas na Lei 11.668/2008, bem como, suas obrigações, gerando uma verdadeira confusão jurídica.

VII) DA CONSTITUCIONALIDADE DAS REGRAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 6°, 7° E 10° DA LEI 11.668/2008

Como aplicação máxima do conceito de legislar tem-se que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, tampouco o ato jurídico perfeito e de fato a Lei 11.668/2008 não viola estes preceitos fundamentais.

Assim determina a regra contida no inc. XXXVI do art. 5° de nossa Constituição:

> ***"XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;".***

Conforme a lição do ilustre professor Kildare Gonçalves Carvalho, tem-se que:

> "***Tem-se por direito adquirido, segundo estabelece o art. 6°,§ 2°, da Lei de Introdução do Código Civil, aquele que o seu titular ou alguém que por ele possa exercer, como aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixado, ou condição preestabelecida, inalterável, a arbítrio de outrem. Pontes de Miranda, ao tratar do dificílimo tema, define o direito adquirido como "o direito irradiado de fato jurídico, quando a lei não o concebeu como atingível pela lei nova"".***(DIREITO CONSTITUCIONAL, ED. DEL REY, CARVALHO, KILDARE GONÇALVES, 14 ED., PG 746).

Clóvis Beviláqua dá ao direito adquirido o seguinte conceito:

> *"Os direitos adquiridos, que as leis devem respeitar, são vantagens individuais, ainda que ligadas ao exercício de funções públicas".* (TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL, BEVILÁQUA, CLÓVIS, PG 19).

Quanto ao ato jurídico perfeito tem-se que:

> *"Ato jurídico perfeito, de acordo com a Lei de Introdução ao Código Civil (art. 6°, §1°), é aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Pontes de Miranda sustenta que ato jurídico perfeito "é o negócio jurídico, ou o ato jurídico stricto sensu; portanto, assim as declarações unilaterais de vontade, como os negócios jurídicos bilaterais, assim os negócios jurídicos, como as reclamações, interpelações, a fixação de prazo para a aceitação de doação, as comissões...*
>
> *Portanto, é perfeito o ato jurídico que reúna os elementos substanciais previstos na lei civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não vedada por lei. Ressalte-se ainda que, embora não consumado, o ato jurídico perfeito que se encontra apto a produzir efeitos tem garantia a sua execução contra a lei nova que não os pode regular, subordinados que ficam à lei antiga".*

Importante aqui fazer uma breve análise e apontamento ao contrato de franquia ao qual a Lei 11.668/2008 pretende regulamentar.

Em primeiro lugar que se trata de um contrato revestido de legalidade, visto que submetido está à mesma lei anterior que os orienta na lei atual, qual seja, a regra contida no §3°, do art. 2°, da Lei 6.538/1978.

Em segundo lugar, por preencher os requisitos de um ato jurídico perfeito, jamais poderia ser extinto em decorrência da Lei.

Não obstante, considerando a ADPF 46, os últimos julgados no STJ e o próprio pronunciamento do TCU, verifica-se que a Lei 11.668/2008, procurou respeitar, como supramencionado a coisa julgada, uma vez definido que:

"o contrato de franquia postal **não pode ter sua natureza jurídica modificada**, que o contrato de franquia **não se confunde com o contrato de prestação de serviços públicos**, que a Lei de Franquia postal de fato **está subsidiada a Lei 8.666/1993**, portanto está **submetida à exceção da regra contida no art. 37, inciso XXI** da Constituição Federal, que o contrato de franquia **não se equipara às concessões e permissões**,

ou seja, prestação de serviços públicos (art. 175), que o serviço público postal **não pode ser transpassado para o setor privado**, logo **não pode ser transpassado para franquias**, que exercem atividades auxiliares, portanto não se trata de licitação na modalidade concorrência como se tratasse de prestação de serviço público decorrente de uma concessão, mas sim de contratação direta".

Em momento algum, as partes contratantes, franqueado e franqueador, demonstraram o animo de extinguir tal relação jurídica, senão em face da determinação inconstitucional da regra contida no art. 9° e seus parágrafos do Decreto 6.639/2008, objeto da ADI 4437.

Vejam, Eméritos Ministros, não se pode extinguir uma relação jurídica, um ato jurídico perfeito, sem o consentimento das partes ou ainda qualquer ânimo que justificasse tal conduta.

Não bastasse a inexistência de previsão na Lei 11.668/2008, que apenas tinha por objetivo a regularização e manutenção dos contratos de franquia, quiçá, através de uma alteração advinda de um Decreto, cuja característica e natureza é dar condições para a possibilidade de se cumprir a lei.

Via de regra, a Lei 11.668/2008 teve como objetivo proteger outro preceito fundamental, qual seja: o inc. XIII do art. 5° da Constituição, quando cria uma nova modalidade - AGF, ou seja: **o direito à livre iniciativa e o princípio do livre exercício do trabalho.**

É possível assim verificar a Lei ao definir e optar por uma forma especial de contratação fundada na exceção prevista na regra contida no art. 37 inciso XXI, por certo tinha como pretensão evitar o desequilíbrio entre o franqueado de 17 anos de Know How e uma empresa sem qualquer experiência, bem como evitar que a regra contida no art. 3° da Lei 8.666/1993 fosse violada, bem como o principio da igualdade.

Ainda quando o Prof. Marçal Justen Filho faz menção a tais pressupostos tem-se que:

> ***"Na primeira categoria, encontram-se os casos de inviabilidade de competição por ausência de pluralidade de sujeitos em condições de contratação. São as hipóteses em que é irrelevante a natureza do objeto, eis que a inviabilidade de competição não decorre***

> ***diretamente disso. Não é possível a competição porque existe um único sujeito para ser contratado.***
>
> ***Na segunda categoria, podem existir diversos sujeitos desempenhando a atividades que satisfaz a necessidade estatal. O problema da inviabilidade de competição, não é de natureza numérica, mas se relaciona com a natureza da atividade a ser desenvolvida ou de peculiaridade quanto à própria profissão desempenhada. Não é viável a competição porque características do objeto funcionam como causas impeditivas".*** (COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 14 ED. EDITORA DIALÉTICA, FILHO, MARÇAL JUSTEN, PG. 357/358).

Assim é possível entender que fica evidente a ausência de mercado concorrencial, tanto é verdade que a própria requerida, retira do edital a questão referente à qualificação técnica e conforme consta em sua própria resposta à impugnação administrativa, deixa evidente que, se exigisse tal qualificação **tornaria a concorrência inviável**.

Assim se manifesta a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos quando da resposta à impugnação administrativa:

> *"Quanto à exigência de experiência (capacidade técnica), **embora prevista em lei,** decorre antes de tudo **do poder do exercício discricionário que é conferido ao administrador público**, o qual **optará pela solução que melhor satisfaça a conveniência e oportunidades públicas**. A exigência do ACT deve ser justificada (motivada) **a sua real necessidade uma vez que a utilização aleatória poderá vir a cercear a competição no certame**, in correndo na vedação prevista no art. 3°, §1°, da Lei 8.666/1993". Sobre o assunto já se pronunciou o TCU, ao dispor que, in verbis, pode-se concluir que a entidade que promove a licitação deve **fundamentar adequadamente a exigência da capacidade técnica**, demonstrando de forma **inequívoca** sua **imprescindibilidade e pertinência** em relação ao objeto licitado....Na hipótese, tal exigência não se mostra viável,*

porquanto ***restringiria o universo de interessados*** *no certame,* ***apenas aos atuais franqueados****".***(RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DATADA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2010, PG. 02, CARTA 0063/2010, CEL 001/2009/DR/PR).

Veja Emérito Ministro, apenas com esta resposta a própria ECT define que se cabe ao Administrador Público o poder de não respeitar a lei, a ponto de deixar de cumprir um pressuposto tão importante, ainda mais por se tratar da modalidade de concorrência, qual seja, a habilitação e capacidade técnica, por qual motivo esta respeitando a lei de franquia postal, cujos vícios são aparentes e ainda pende de várias discussões inclusive acerca de sua inconstitucionalidade decorrente do decreto.

A justificativa que a ECT ousa, acerca do poder discricionário que lhe serve nada mais é do que, eu posso e quero desrespeitar a regra contida no art. 27, inc. II da Lei 8.666/1993, para respeitar a regra contida no art. 2° do Decreto 6.639/2008, todavia ao avaliar desta forma, a Administração Pública, no caso a ECT viola e fere outras normas e princípios rígidos constitucionais.

Outrossim, a própria ECT com a resposta acima transcrita, aceita o fato de que nenhuma outra empresa poderia concorrer com franquias de correio já existentes, aceitando também o fato de que se trata de um **serviço essencial e que necessita de especialidade**, caso contrário qualquer um estaria habilitado, não precisando de treinamento.

Por fim, a ECT em momento algum comprova de forma inequívoca a desnecessidade de comprovação da habilitação e capacitação técnica, até porque se trata de um serviço essencial público, cujo treinamento não poderia ser inferior a seis meses, afora acompanhamento intenso de auditores e fiscais, não sendo possível qualquer empresa participar do certame e ser considerada apta a prestar um serviço de tamanha importância em apenas duas semanas.

Apoiar esta idéia seria o mesmo que fadar, o nosso orgulho postal, ao insucesso, e daí sim, colocá-los novamente nas mãos de empresas privadas.

No que tange a ausência de mercado concorrencial e de objetividade na seleção do objeto Marçal Justen Filho tem o seguinte posicionamento:

> *"Outra hipótese consiste nas características do mercado privado envolvendo o tipo de prestação pretendida pela Administração Pública. Embora possam existir diferentes alternativas para satisfação do interesse sob tutela estatal, não se configura um mercado na acepção de conjunto de fornecedores em disputa permanente pela contratação a qualquer tempo, eis que os particulares em condições de executar a prestação não competem entre si formulando propostas. Esses particulares aguardam propostas de possíveis interessados, não estabelecendo diferença mesmo em relação ao setor público.* ***Ou seja, configura-se um mercado peculiar, eis que não existe a dimensão concorrencial encontrada no âmbito de compras, obras e outros serviços. Daí a referência à inexistência de um mercado concorrencial.***
>
> *A hipótese imediatamente considerada acima, também se caracteriza, como regra, pela impossibilidade de seleção segundo critérios objetivos. Existem diferentes alternativas, mas a natureza personalíssima da atuação do particular impede julgamento objetivo, é impossível definir com precisão uma relação custo benefício, Ainda que seja possível determinar o custo,* ***os benefícios que serão usufruídos pela Administração são relativamente imponderáveis.***
>
> *Essa incerteza deriva basicamente da natureza subjetiva da avaliação, eis que a natureza da prestação envolve fatores intelectuais, artísticos, criativos e assim por diante. Não há critério objetivo de julgamento, a competição perde sentido.* (COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 14 ED. EDITORA DIALÉTICA, FILHO, MARÇAL JUSTEN, PG. 357/358)".

Ora, por certo que a requerida ao responder a impugnação administrativa desta forma: "*Quanto à exigência de experiência*

(capacidade técnica), ***embora prevista em lei,*** *decorre antes de tudo* ***do poder do exercício discricionário que é conferido ao administrador público****, o qual* ***optará pela solução que melhor satisfaça a conveniência e oportunidades públicas”****,* deixou claro que neste caso pelo menos em momento algum optou pela melhor solução.

Pois se o preço já estava fixado no edital, ou seja, EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA, MELHOR PROPOSTA TECNICA, COM PREÇO FIXADO NO EDITAL, a requerida não corria o risco de contratar pelo maior preço, todavia optou em possibilitar que qualquer um participasse da licitação correndo o risco de ter um serviço público essencial mal executado.

E ainda, para aqueles que não tem experiência ainda terá que dispor do dinheiro da Administração Pública para fornecer treinamentos, consultorias, dentre outras questões que por certo serão geradas, onerando os cofres da requerida.

Tem-se então a teoria da efetivação da melhor contratação, qual seja, se existe um preço que já esta pré-fixado, a Administração Pública tem que por obrigação, perseguir a melhor contratação, ou seja, contratar aquele que melhor esteja qualificado tecnicamente para executar o objeto do contrato.

Por tais motivos, é que se faz necessário esta ADC, cuja finalidade é a proteção do bem maior fincado em nossa Constituição Federal, os seja, os preceitos fundamentais.

No mesmo norte, passemos a analisar a regra contida no inciso IV do art. 15 da Lei 8.987/1995, à qual a Lei 11.668/2008 também esta subsidiada, qual seja:

> *“...*
>
> *IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital”;*

Veja Eméritos Ministros, o legislador em hipótese alguma diz que a Lei 11.668/2008 esta subsidiada ao caput do art. 15, mas tão somente ao inciso IV.

A Lei 11.668/2008 determina que o **critério de julgamento** seja o previsto no inciso IV do caput do art. 15 e não que a

contratação seja realizada através de licitação conforme o caput do art. 15 e o inciso IV.

Pois bem, veja o que delimita em sua obra Marçal Justen Filho acerca da contratação direta:

> *"...Essa flexibilidade não foi adornada de discricionariedade. O próprio legislador determinou as hipótese em que se aplicam os procedimentos licitatórios simplificados. Por igual, definiu os casos de não incidência do regime formal de licitação. A contratação direta não significa que são inaplicáveis os princípios básicos que orientam a atuação administrativa. Nem se caracteriza uma livre atuação administrativa. O administrador será obrigado a seguir um procedimento administrativo determinado, destinado a assegurar (ainda nesses casos) a prevalência dos princípios jurídicos fundamentais.* ***Permanece o dever de realizar a melhor contratação possível, dando tratamento igualitário a todos os possíveis contratantes***.
>
> *Portanto,* ***a contratação direta não significa eliminação de dois postulados consagrados a propósito da licitação. O primeiro é a existência de um procedimento administrativo. O segundo é a vinculação estatal `a realização de suas funções"***. (COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 14 ED. EDITORA DIALÉTICA, FILHO, MARÇAL JUSTEN, PG. 295)

Desta forma, fica evidente, o motivo que levou a Lei 11.668/2008 a compilar determinadas leis, dando como parâmetro a forma, ou seja**,** **o ato formal** que deveria ser praticado, seguido pela **Administração Pública quando da contratação direta, adjudicação direta,** qual seja, pela regra do inciso IV do caput art. 15 da Lei 8.987/1995.

Ainda em citação ao mesmo autor:

> *"A contratação direta submete-se a um procedimento administrativo, como regra. Ou seja, ausência de licitação* ***não equivale*** *a* ***contratação informal****, realizada*

> *com quem a administração bem entender, sem cautelas nem documentação. Ao contrário, a contratação direta exige* ***um procedimento prévio****, em que a observância de* ***etapas e formalidades é imprescindível****.*
>
> *A diferença residirá em que, no momento de definir as fórmulas para contratação, a Administração constatará a inaplicabilidade das regras acerca de licitação".* (COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 14 ED. EDITORA DIALÉTICA, FILHO, MARÇAL JUSTEN, PG. 296).

É possível assim entender que para a contratação direta, ou seja, para a adjudicação direta, o que se pretende é avaliar e produzir a melhor proposta possível e nada melhor para isso do que ter como parâmetro melhor proposta técnica com preço fixado no edital, já que se esta falando de um serviço essencial público e cuja especialidade não é corriqueira, tampouco cabe a qualquer um seu exercício.

No mesmo diapasão, não é possível admitir que o contrato de franquia, seja o contrato de franquia atual, seja o contato de franquia postal, trate-se de uma concessão de prestação de serviço público, conforme determina a regra contida no art. 175 da Constituição Federal:

> *"Art. 175 – Incumbe ao poder público na forma da lei, ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos":*

Veja Eméritos Ministros, que o contrato de franquia não possui características de um contrato de prestação de serviços, como bem definiu o STJ em recentes decisões:

"RECURSO ESPECIAL Nº 873.440 - RS (2006/0169502-8) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE : FLORES CARLESSO E CARLESSO LTDA ADVOGADO : RICARDO MELLO BOSCHI RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SANTA MARIA PROCURADOR : PAULO RUY RODRIGUES LEAL E OUTRO(S) EMENTA TRIBUTÁRIO. ISS. EMPRESA FRANQUEADA QUE PRESTA SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. DECRETO-LEI 406/68 E LC 56/87 VIGENTES À ÉPOCA. PERÍODO ANTERIOR À LC 116/03. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Os serviços prestados por empresas franqueadas que

*realizaram atividades postais e telemáticas, sob a égide da LC 56/87, não são tributados pelo ISS. (Precedentes:REsp 783125 / RS , 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 29/08/2006 RESP 403.799-MG, DJ de 26.04.2004, Rel. Min. Franciulli Netto; RESP 189.225-RJ, DJ de 03.06.2002, Rel. Min. Peçanha Martins). 2. A edição da LC 116/03, que entrou em vigor a partir de 01/01/2004, enunciou, no item 26.01 de sua lista anexa, como hipótese de incidência do ISS, os "serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas". Destarte, a partir de então, ressoa indubitável a incidência da exação sobre os serviços postais e telemáticos realizados pelas agências franqueadas dos Correios. 3. Sob esse enfoque, é cediço no STJ que a LC 116/03 somente entrou em vigor a partir de 01/01/2004, não atingindo, portanto, o período sub judice, qual seja, de 1997 a 2002. 4. Deveras, a aferição da natureza do contrato, em face da sua atipicidade, demanda revolvimento do contexto fático-probatório, porquanto enseja a análise apurada de suas cláusulas, providência inviável no âmbito do recurso especial, conforme dispõe a Súmula 05/STJ, consoante já assentado pela C. 1ª Turma. (Precedente: AGRESP 442225 / PR, PRIMEIRA TURMA, DJ 30.08.2004) 5. In casu, conquanto o acórdão recorrido tenha esposado entendimento contrário ao desta Corte Superior, no sentido de que ""(...) seja antes ou após a LC 116/03, não há falar em inexistência de relação jurídica tributária, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos da inicial era medida que se impunha", o juízo monocrático, com ampla cognição fático probatória, **asserindo a natureza de franquia relativa ao contrato em tela, assim se manifestou, in verbis**: "Cotejando, assim, a definição legal da espécie contratual e aquilo que de fato contrataram as partes, não há como negar que realmente se está diante de pacto de franquia empresarial, porquanto presentes, na definição, todos os requisitos a tanto legalmente instituídos.(...) Como ressaltado, a definição do objeto e das tarefas contratuais dão conta de que a franqueada **exerceria as atividades sob a marca dos correios**, formalizando ACF (agência de correio franqueada), **e distribuindo**, em nome próprio, os serviços prestados **originalmente por aquele**, cobrando as respectivas tarifas e repassando ao franqueador a remuneração ajustada pela cessão da marca. Não me parece, portanto, que a atividade descrita se enquadre na definição do art. 1º da Lei 4.886/65, regente da representação comercial e de cujos termos, a seguir transcritos, já se pode de pronto verificar a inconfundível diversidade entre as referidas práticas.(...)E se assim é, forçoso reconhecer que as rendas decorrentes dos estritos serviços advindos daquela contratação não estão sujeitos à*

tributação pelo ISSQN, porquanto não incluídos na lista anexa à Lei Complementar 56/87 tampouco no rol do art. 10 da LC Municipal 01/02 (fls. 68/89), sendo certo, além disso, que, ante o inafastável princípio da legalidade tributária, referido elenco não pode admitir qualquer espécie de interpretação extensiva.(...)Relativamente à venda de títulos de capitalização levada a efeito pela Autora - que, inclusive, assim reconheceu na inicial -, mais especificamente no que tange à comercialização da chamada "telesena" (fl. 90), contudo, deve prosperar o entendimento defensivo. Em primeiro lugar, porque esta espécie de serviço não consta dentre aqueles exclusivamente cedidos pela EBCT em função da franquia (postais e telemáticos); e também, porque esta atividade se enquadra, é inegável, no item 61 do art. 10 da LC nº 01/02. O mesmo se diga em relação ao serviço de fotocópias (xerox) igualmente prestado pela Autora (fl. 191), não abrangidos pela imunidade tributária, algo que observo apenas para constar, já que a isenção quanto a este sequer foi postulada nesta ação." (fls. 233/237) 6. Recurso Especial provido, para determinar a não-incidência do ISS sobre os serviços prestados exclusivamente em função do contrato de franquia celebrado com a EBCT, anteriores a 01/01/2004, data em que entrou em vigor a LC 116/03".

*"Processo AgRg nos EDcl no REsp 786861 / DFAGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2005/0168210-0 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 18/12/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2009 Ementa TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ISSQN. FRANQUIA. FATO GERADOR POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LC N. 116/03 (ITEM 26.01 DO ANEXO). INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A situação tributária das franquias no que tange à exigência de ISSQN deve ser apreciada sob dois enfoques. 2. Na vigência da Lei Complementar n. 56/87, tinha-se verdadeira hipótese de não-incidência, **já que os contratos de franquia, por terem causa e conteúdo próprios (Lei n. 8.955/94), não se confundiam com os contratos de prestação de serviços** (esses sim figurantes do rol trazido por aquele diploma normativo, que deu nova redação ao anexo do Decreto-lei n. 406/68). Precedente. 3. Com a edição da Lei Complementar n. 116/03 - que entrou em vigor apenas em 1.1.2004 -, as franchising, de forma geral, foram expressamente incluídas na lista de serviços que tornam exigível o tributo (item 10.04 do anexo daquela lei complementar). As franquias relacionadas à prestação de serviços postais*

ganharam regulamentação no item 26.01. Precedente. 4. Na ausência de declaração de inconstitucionalidade desses últimos dispositivos, permanecem eles válidos e produzindo efeitos. 5. Agravo regimental não-provido".

***"AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 953.840 -RJ (2007/0115791-3) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. FRANQUIA (FRANCHISING).NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA (PLEXO INDISSOCIÁVEL DE OBRIGAÇÕES DE DAR, DE FAZER E DE NÃO FAZER). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONCEITO PRESSUPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AMPLIAÇÃO DO CONCEITO QUE EXTRAVASA O ÂMBITO DA VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PARA INFIRMAR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.** *O ISS na sua configuração constitucional incide sobre uma prestação de serviço, cujo conceito pressuposto pela Carta Magna eclipsa ad substantia obligatio in faciendo, inconfundível com a denominada obrigação de dar. Outrossim, a Constituição utiliza os conceitos de direito no seu sentido próprio, com que implícita a norma do artigo 110, do CTN, que interdita a alteração da categorização dos institutos. Consectariamente, qualificar como serviço a atividade que não ostenta essa categoria jurídica implica em violação bifronte ao preceito constitucional, porquanto o texto maior a utiliza não só no sentido próprio, como também o faz para o fim de repartição tributária-constitucional (RE 116121/SP). Sob esse enfoque, é impositiva a regra do artigo 156, III, da Constituição Federal de 1988, verbis : "Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (...)" A dicção constitucional, como evidente, não autoriza que a lei complementar inclua no seu bojo atividade que não represente serviço e, a fortiori , obrigação de fazer, porque a isso corresponderia franquear a modificação de competência tributária por lei complementar, com violação do pacto federativo, inalterável sequer pelo poder constituinte, posto blindado por cláusula pétrea. O conceito pressuposto pela Constituição Federal de serviço e de obrigação de fazer corresponde aquele emprestado pela teoria geral do direito, segundo o qual o objeto da prestação é uma conduta do obrigado, que em nada se assemelha ao dare, cujo antecedente necessário é o repasse a outrem de um bem preexistente, a qualquer título, consoante a homogeneidade da doutrina nacional e alienígena, quer de Direito Privado, quer de Direito Público. Deveras, o Código Tributário Nacional, como de sabença recepcionado como lei complementar, tratava dos Impostos sobre Serviços de Qualquer natureza, em seus artigos 71 a 73, revogados pelo*

Decreto-Lei nº 406/68, que estabeleceu normas gerais de Direito Financeiro, aplicáveis ao ICMS e ao ISS. Consoante o aludido decreto-lei, constituía fato gerador do ISS a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço constante da lista anexa ao diploma legal, ainda que sua prestação envolvesse o fornecimento de mercadoria. Na citada lista de Serviços, anexa ao Decreto-Lei 406/68, com a redação dada pela Lei Complementar 56, de 15 de dezembro de 1987, encontrava-se elencada a atividade de "Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia (franchise) e de faturação (factoring) (excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);" (Item 48). Destarte, a franquia não era listada como serviço pelo legislador complementar, mas, sim, as atividades de corretagem, agenciamento e intermediação que a tivessem por objeto, panorama que restou modificado pela Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, que revogou os artigos 8º, 10, 11 e 12, do Decreto-Lei 406/68, bem como a Lei Complementar 56/87, entre outros dispositivos legais. Os Itens 10 e 17, da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, elencam, como serviços tributáveis pelo ISS, o agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de leasing , de franchising e de factoring (Subitem 10.04), bem como a franquia (Subitem 17.08). ***A mera inserção da operação de franquia no rol de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 não possui o condão de transmudar a natureza jurídica complexa do instituto, composto por um plexo indissociável de obrigações de dar, de fazer e de não fazer. Destarte, revela-se inarredável que a operação de franquia não constitui prestação de serviço (obrigação de fazer), escapando, portanto, da esfera da tributação do ISS pelos municípios.*** *(...)" Os fundamentos de índole notadamente constitucional, sem as quais não sobreviveria o aresto recorrido, impõem timbrar seu núcleo constitucional para, na forma da jurisprudência cediça na Corte, não conhecer do recurso especial (Precedentes do STJ:* ***REsp 912.036/RS****, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 08.10.2007;* ***AgRg no Ag 757416/SC****, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 03.08.2006;* ***AgRg no Ag 748334/SP****, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 30.06.2006;* ***REsp 754545/RS****, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 13.03.2006;* ***AgRg no REsp 778173/MG****, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 06.02.2006; e* ***AgRg no REsp 658392/DF****, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 21.03.2005).* ***VOTO O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator):*** *A decisão agravada ostenta o seguinte teor: (...) Com efeito, cinge-se a controvérsia à incidência ou não de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN sobre a atividade de franquia (franchising). Prima facie, impende inquirir do critério material integrante da regra-matriz de incidência tributária do ISS, a fim de explicitar o comportamento humano abstratamente descrito na hipótese normativa e que, no dizer de Amílcar Falcão, representa 'fato econômico de relevância jurídica'. (...)*

Carlos Maximilian ensina que se deve afastar as interpretações impossíveis ou ilógicas: pois, é da mais gritante falta de lógica, tanto comum, como jurídica, a interpretação que pretende conferir a esse preceito o significado de conferir à lei complementar o definir "serviços de qualquer natureza", para efeito de abrir espaço à competência tributária dos Municípios. Tudo isto foi amplamente exposto por Souto Maior Borges, no seu clássico "Lei Complementar Tributária"." (in obra citada, 2ª ed., rev. ampl. e atual., Ed. Dialética, São Paulo, 2005, págs. 36/42) A delimitação do conceito de serviço deve se ater aos pressupostos constitucionais. ***Em termos mais rigorosos, todas características definitórias do definiendum "serviço" estão postas na Constituição Federal. A lei complementar somente pode acrescer características acidentais ou acessórias. Mas não pode estabelecer, como serviço, o que não o é. Por conseqüência, qualquer grandeza eleita para figurar na base de cálculo do ISS que não se origine das características definitórias constitucionais de "serviço" encontra-se estigmatizada pelo vício da inconstitucionalidade." (in obra citada, Organização de Heleno Taveira Tôrres, 1ª Ed., Ed. Manole, São Paulo, 2004, págs.236/237)*** *Deveras, como bem elucida Marcelo Caron Baptista, na obra "ISS: Do Texto à Norma", a exação em tela somente pode incidir se houver a realização de serviço para terceiro, porquanto ser necessária a existência de uma relação "envolvendo, pelo menos, duas pessoas: o realizador e o tomador do serviço". De acordo com o aludido autor, a prestação de serviço, núcleo do critério material da hipótese de incidência do ISS, ostenta natureza jurídica de obrigação de fazer, identificável pelo fim específico a que visa o contrato celebrado entre as partes, a despeito da existência de prestação-meio consistente em um "fazer" ou em um "dar":* ***"4.1.10. A prestação de serviço como prestação "de fazer"*** *A hipótese de incidência do ISS, sopesadas as informações colhidas do sistema jurídico, em confronto com a experiência empírica, afasta as prestações negativas de "não fazer" e de "não dar", ainda que, de qualquer modo, caracterizem um fazer em sentido lato, uma ação omissiva. Mesmo que existam várias possibilidades da prestação objeto da relação jurídica identificar-se com um comportamento omissivo, aquele correspondente a "prestar serviço" em benefício de terceiro, mediante remuneração, parece totalmente incompatível com a idéia de uma abstenção. Pelo menos fazemos questão de confessar o fato de não termos vislumbrado sequer uma hipótese nesse sentido. Partindo desse pressuposto, resta analisar, diante das prestações positivas, a distinção entre as de dar e as de fazer. Quanto às típicas prestações de dar e de fazer a explicação não comporta maiores controvérsias. Prestação de dar ocorre quando a ação titularizada pelo devedor se destina à tradição de um bem. Prestação de fazer é aquela que se opera pela ação pessoal do devedor, cuja relevância não está na tradição de bem, ainda que ela possa eventualmente ocorrer. A hipótese de incidência do ISS refere-se às prestações de fazer, ou seja, aquelas marcadas pela ação pessoal do devedor. Essa conclusão não se alcança com base na eficácia normativa experimentada por esse tributo ao longo do tempo mas por*

meio de indicativo colhido da própria Constituição Federal. ***A palavra "serviços", constante do artigo 156, III, do Texto, afasta, por incongruência semântica, a idéia de prestação de dar, eis que não envolve, na sua essência, qualquer coisa, seja material, seja imaterial. A ação pessoal do prestador, no entanto, não rejeita o emprego de bens materiais ou imateriais, mercadorias ou produtos industrializados, bem como de equipamentos. Ao contrário, a maior parte dos serviços requer o emprego de tais bens, sob pena de restar inviabilizada a prestação. Mas o comportamento tributado pelo ISS é aquele em que o esforço pessoal do devedor se sobrepõe aos materiais e equipamentos eventualmente aplicados.*** *Colabora, também, nesse sentido, o confronto de "serviços" com a materialidade de outros tributos, especialmente o ICMS -no quanto se refere a operações relativas à circulação de mercadorias -e o* ***IPI*** *- exceto sobre importação de produtos. Ainda que o critério material destes últimos não se resuma a uma prestação de dar, porque sua essência está na realização de operações jurídicas, elas, invariavelmente, giram em torno de um bem material, de uma mercadoria ou de um produto industrializado, o que não ocorre com o ISS. Este tributo, portanto, é dirigido preponderantemente à atividade pessoal do sujeito passivo da relação jurídica patrimonial. O tomador do serviço, quando o contrata, objetiva não a apropriação de um bem mas o resultado do esforço e da capacidade, física ou intelectual, da outra parte, ainda que esse resultado se expresse, no mundo fenomênico, por meio de um bem material. Prestação de serviço, por isso, é prestação jurídica de fazer. "* ***4.1.11 Prestação-meio e prestação-fim*** *Como desdobramento da distinção fundamental entre prestações de dar e de fazer, surge a necessidade de admitir que um esforço humano, no contexto de uma relação jurídica contratual, não assegura ao intérprete, por si só, tratar-se de uma prestação de fazer, e ainda tributável pelo ISS. Muitas vezes a complexidade dos fatos jurídicos torna deveras difícil estabelecer os contornos precisos que permitem apartar, das prestações em geral, as figuras do dar e do fazer, o que acarreta importantes reflexos para a compreensão da norma tributária, ocasionando, em algumas vezes, dúvidas razoáveis sobre a incidência de determinados tributos diante de específicas hipóteses. A presença do contrato é mais do que o primeiro divisor de águas para limitar o conjunto de comportamentos passíveis de tributação pelo ISS. É dele que aflora a natureza jurídica tributária da prestação. Centra-se a investigação, por isso, no acordo de vontades. As relações jurídicas são estabelecidas em torno de uma prestação que, quando adimplida, extingue o dever jurídico do sujeito passivo. Todo contrato visa a um fim específico. É um dos meios pelos quais o homem busca a satisfação de suas necessidades, relacionando-se com terceiros. Exatamente da finalidade do contrato é que se extrai a natureza da prestação. Imprescindível estabelecer, pois, um critério jurídico pelo qual seja possível identificar o* ***comportamento-fim pactuado*** *, aquele que, ocorrido, faz extinguir o dever jurídico. As lições da doutrina são precisas sobre o tema. Para ORLANDO GOMES "a distinção entre as*

obrigações de dar e as de fazer deve ser traçada em vista do interesse do credor (...). Nas obrigações de dar, o que interessa ao credor é a coisa que lhe deve ser entregue, pouco lhe importando a atividade do devedor para realizar a entrega. Nas obrigações de fazer, ao contrário, o fim é o aproveitamento do serviço contratado" . O interesse do credor, portanto, pode estar voltado, preponderantemente, para um bem ou para um comportamento do devedor. No primeiro caso, a prestação a que faz jus o credor é a de dar; na segunda, a de fazer. Entre o seu surgimento e a sua extinção, a relação -colocado à parte o direito à remuneração -fica na dependência do comportamento-fim imputado ao devedor. Tal comportamento pode ser um ato simples, unitário, facilmente identificado; ou pode ser complexo, caso em que requer a observância de etapas, para que o fim contratado seja atingido. (...) Em outras palavras, serviço faz-se, não se dá. Em suma: nas obrigações ad dandum ou ad tradendum consiste a prestação em entregar alguma coisa (dar), enquanto que as infaciendo se referem a ato ou serviço a cargo do devedor (prestador). (...) ***Franquia: Utiliza-se o termo franquia ou franchising. O vocábulo franchising provém do inglês franch, que teve origem no francês medieval franc, surgindo francher, no sentido de outorga de privilégio, uma forma de autorização ou abandono de servidão. Franchising, do verbo to franch, constitui um instrumento destinado a fomentar processos de venda e distribuição em série, com características específicas.(...)*** *No Brasil, segundo Rubens Requião (1978:43), o contrato examinado apareceu sob a forma de concessão mercantil, como no técnica de distribuição de filmes cinematográficos das grandes empresas que detinham a marca dos conceituados estúdios norte-americanos, passando a ser posteriormente utilizado pela indústria. As empresas importadoras de veículos também começaram a utilizar o instituto, mediante concessão exclusiva, para a distribuição dos veículos importados que ingressaram em nosso país. (...)* ***O contrato de franquia envolve cessão de marca, transferência de tecnologia, assistência técnica. É um conjunto de fatores e não prestação de serviços. Esta, quando existente, é indissociável dos outros fatores. O franqueado não presta serviços ao franqueador ou vice-versa. Franquia não é serviço. É cessão de direitos. A supervisão de rede, orientação, treinamento do franqueado e de seus funcionários, escolha de ponto é obrigação de meio para a realização da franquia e não serviço . A lei tributária não pode estabelecer um conceito diverso do previsto no Direito Comercial (art. 110, do CTN) para alterar a definição do instituto e considerá-lo como serviço, que não é. (...) A franquia é um contrato complexo. Não é exatamente serviço. (...)" (In obra citada, 7ª ed., Ed. Atlas, São Paulo, 2006, págs. 272/278)*** *Aires F. Barreto bem elucida a natureza jurídica do contrato de franquia, verbis: "A franquia é materializada por contrato de cunho mercantil que resulta do acordo de vontades entre o titular da marca (designado concedente ou franqueador) e o cessionário desses direitos de uso de marca, intitulado franqueado. Para atingir o fim do contrato, consubstanciado no direito de uso dos produtos ou serviços representados pela*

*marca, o franqueado ou franqueador assumem deveres heterogêneos -gerados para ambas as partes -visando à consecução do contrato, qual seja, o direito de uso dos produtos ou serviços representados pela marca. O conteúdo do contrato de franquia envolve obrigações de dar, de fazer e de não-fazer. Disso decorre a complexidade do contrato de franquia e a inexorável impossibilidade de dissociação dos diversos elementos do contrato, para fins de consideração jurídica . (...) Não é possível seccionar o contrato de franquia em vários outros, para considerá-lo de per si. O contrato de franquia é contrato misto, complexo, indivisível. Não se confunde com contratos coligados . Como ensina Orlando Gomes, quando há contratos coligados, existe duplicidade contratual, cada qual com causa própria. A união dos contratos, muito embora consustanciam-se num mesmo instrumento, concluindo-se num mesmo átimo, é exógena ou externa. Cada qual mantêm individualidades e autonomias próprias. Não há que se cogitar de fusão, isto é, embora ocorra a acumulação, não se tem por resultado um contrato unitário. Na estruturação e na eficácia, distinguem-se os contratos coligados dos contratos mistos. A coligação dos contratos não acarreta a perda da individualidade dos contratos, ao contrário do misto. Na coligação, os contratos são autônomos, mas se ajustam, unem-se em relação de união com dependência, de união alternativa ou união meramente exterior. (...) A seu turno, nos contratos mistos, dentre suas subsespécies, destacam-se os contratos complexos, em que as diversas prestações correspondem várias contraprestações. No contrato coligado, cada figura contratual apresenta autonomia funcional, mesmo naquela hipótese onde um dos contratos não possa existir autonomamente. Já no contrato complexo (misto), há uma unidade de causa, uma função jurídica específica, que somente é preenchida pela conjugação de diversas cláusulas e condições. É o que se verifica irretorquivelmente no contrato de franquia. (...)**Em suma, a franquia é um contrato misto, do tipo complexo. Ao franqueador incumbe, fundamentalmente, conceder licença para o uso da marca. A essa obrigação se conjugam elementos: contratos completos, prestações típicas inteiras, ou elementos mais simples de outros contratos. Tem-se aí uma unidade contratual. Não há como separar esses diversos elementos porque, absorvidos, fundidos, amalgamados no contrato de franquia, perdem totalmente sua individualidade, deixando de ser autônomos. Dentre eles, despontam as atividades necessárias à consecução da franquia, sob pena de desnaturação do contrato .**" (In "ISS na Constituição e na Lei", 2ª ed., Ed. Dialética, São Paulo, 2005, págs. 210/213) Arremata o insigne tributarista que "é inequívoca a intributabilidade, por via de ISS, da atividade de franquia", uma vez que "o franchising (espécie de cessão de direitos) não se subsume ao conceito constitucional de serviços tributáveis por esse imposto municipal; conseqüentemente, dita atividade econômica não está abrangida pela competência tributária atribuída aos Municípios pela Constituição Federal", o que torna inarredável a ofensa ao texto constitucional pelo Subitem 17.08 da*

Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 (In obra citada, pág. 219). ***Forçoso relembrar que, consoante o voto que se sagrou vencedor no Plenário da Excelsa Corte (RE 116121/SP), "há de prevalecer a definição de cada instituto, e somente a prestação de serviços, envolvido na via direta o esforço humano, é fato gerador do tributo em comento".*** *A mera inserção da operação de franquia no rol de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 não possui o condão de transmudar a natureza jurídica complexa do instituto, composto por um plexo indissociável de obrigações de dar, de fazer e de não fazer. Destarte, revela-se inarredável que a operação de franquia não constitui prestação de serviço (obrigação de fazer), escapando, portanto, da esfera da tributação do ISS pelos municípios. As proposições acima conduzem à inequívoca inconstitucionalidade do subitem 17.08, da relação anexa à Lei Complementar 116/2003, que prevê a incidência do ISS sobre a franquia, por isso que se conjura a incompetência imediata do STJ para a análise de recurso que contenha essa antinomia como essência em face da repartição constitucional que fixa os lindes entre esta E. Corte e a Corte Suprema. Deveras, a mesma competência foi exercida pela Corte Suprema na análise prejudicial dos conceitos de faturamento e administradores e autônomos para os fins de aferir hipóteses de incidência, mercê de a discussão travar-se em torno da legislação infraconstitucional que contemplava esses conceitos, reproduzindo os que constavam do texto maior. Aliás não é por outra razão que o CPC dispõe no artigo 543 que: "Art. 543. Admitidos ambos os recursos, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. (...) § 2º Na hipótese de o relator do recurso especial considerar que o recurso extraordinário é prejudicial àquele, em decisão irrecorrível sobrestará o seu julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal, para o julgamento do recurso extraordinário. (...)" Sobressai, desta sorte, imprescindível a manifestação da Corte Suprema sobre o thema iudicandum, suscitado de forma explícita ou implícita em todas as causas que versam sobre a competência tributária municipal, essência manifesta das decisões que tem acudido ao E. STJ. Assim, as conclusões e premissas de índole notadamente constitucional, sem as quais não sobreviveria o aresto recorrido, impõem timbrar seu fundamento constitucional para, na forma da jurisprudência cediça na Corte, não conhecer do recurso especial. (...) Outrossim, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 10, segundo a qual: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte". Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, com fulcro no artigo 557, caput, do CPC." Destarte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão ora hostilizada, razão pela qual merece a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos. Ex positis , NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental".*

Trata-se por certo as jurisprudências acima colacionadas, de casos análogos, já que tratam de ISS, todavia servem como propósito para definição do conceito que se aplica pelo STJ aos contratos de franquia, inclusive o de franquia postal.

Este fato, é mais um ponto contundente na apuração de que o legislador, sabendo que, um contrato de franquia **tem causa e conteúdo próprio**, conforme amplamente entendem os Ministros do Tribunal Superior, tratando a atividade desempenhada pelo franqueado como de distribuidor inadmissível entender que exista a concessão, bem como, que exista a permissão, pois visam licitar contratos provenientes de uma natureza distinta, da que se encontra no contrato de franquia postal, que em hipótese alguma se iguala a contrato de prestação de serviços.

A condição de se tornar um contrato de franquia, proveniente de um ato administrativo, não transforma sua natureza, como bem definiu o STJ, e nem poderia, tampouco tinha o legislador esta intenção quando do advento da Lei 11.668/2008, pois fez com que a Lei de Franquia Postal ficasse subsidiada a Lei do Franchising.

Desta forma, seja um contrato de franquia de *fast food*, seja um contrato de franquia de Postal, ambos mantém sua natureza própria.

Ainda importante estabelecer que o serviço postal foi considerado pela Excelsa Corte como sendo um serviço publico, todavia quem presta o serviço público é a ECT e não o franqueado.

Assim reza a regra do art. 7° da Lei 6.538/1978:

"DO SERVIÇO POSTAL

Art. 7º - Constitui serviço postal o recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas, conforme definido em regulamento".

Assim define o art. 2° da mesma Lei:

"Art. 2º - O serviço postal e o serviço de telegrama são explorados pela União, através de empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações".

As franquias postais apenas realizam atividade auxiliar, intermediária, não podendo exercer atividade de recebimento, expedição, transporte e entrega.

A **ADPF 46** assim definiu através do voto do Ministro Carlos Britto:

> *"A constituição diz que **são atividades próprias da União**, típicas da União, encarregada a União de mantê-las, a caracterizar, portanto, uma compulsoriedade de prestação. Além de ser um serviço público, típico da União, não pode deixar de ser prestado, daí a Constituição fazer uso do verbo "manter".*
>
> *A compulsoriedade da prestação do serviço me parece um elemento do respectivo regime jurídico. Além dessa titularidade pública Federal, **parece-me não ser passível de transpasse para a iniciativa privada**, mediante os conhecidos institutos da autorização, **da concessão ou da permissão**, vale dizer até – não estou sendo exagerado assim ao asseverar – **que é o único serviço público não passível de transpasse para a iniciativa privada**, mediante os citados institutos. É uma atividade insusceptível de exercício privado. Logo tanto a titularidade, quanto a protagonização da atividade ficam no âmbito do setor público federal".*

Portanto a Lei 11.668/2008 em todo o momento sempre esteve fazendo coro com a Constituição Federal, nunca violando os preceitos fundamentais, motivo pelo qual existe a necessidade de ser analisada a presente Ação Declaratória de Constitucionalidade.

VIII) CONCLUSÃO

A Lei 11.668/2008 não poderia alterar a natureza jurídica do contrato de franquia postal, que tem causa e conteúdo próprio, e nem tinha por objetivo alterá-la, prova deste fato é que o legislador submeteu-a à regra contida no art. 37 inciso XXI da Constituição Federal, cuja mesma recepcionava exceções e não à regra do art. 175 da Constituição Federal.

Assim fez o legislador porque comungava da mesma idéia pacificada em nossa jurisprudência e doutrina acerca da não aplicabilidade, aos contratos de franquia, da natureza jurídica aplicada aos contratos de prestação de serviços, bem como, por entender que a teoria geral dos contratos se aplica também aos contratos administrativos, sobrepondo assim as regras eventualmente originadas da relação entre a Administração Pública e a pessoa jurídica de direito privado.

O legislador entendeu tratar-se de uma atividade essencial para a sociedade, reconhecendo sua especialidade, motivo que o levou a manter num primeiro momento os contratos existentes e expandi-los num segundo momento levando-se em conta a necessidade de regularizá-los e de melhorar o serviço postal – art. 6°, inc. III e IV da Lei 11.668/2008.

O Ato normativo impugnado extrapolou sua função de ato regulamentador, contrariando a regra contida no art. 6° e 7° da Lei 11.668/2008, criando um novo modelo de franquia – AGF – sem qualquer base ou estudo de viabilidade.

Desrespeitar a Lei 11.668/2008, em relação ao que a mesma objetivava, ou seja, manter a atual rede e regularizar os atuais contratos, seria incentivar que a Administração Pública gastasse milhões para efetivamente não fazer nenhuma benfeitoria durável, bem como, desrespeitaria o inciso IV do art. 6° que determina a melhoria do serviço postal.

Sendo assim, *data máxima vênia*, necessário que esta Excelsa Corte, na condição que lhe cabe de Guardião da Justiça, que se encontra em seu mais alto grau, tecida em nossa Carta Magna, declare constitucional as regras acima citadas resguardando assim os preceitos fundamentais e garantindo a soberania do bom direito.

IX) DO PEDIDO

Ante o exposto,

em face dos argumentos supramencionados:

01) Preliminarmente, requer seja julgado procedente o pedido referente ao reconhecimento da legitimidade ativa da autora para propor a presente ADC, conforme fundamentos supramencionados, tendo em vista a natureza do objeto jurídico aqui tutelado, os preceitos fundamentais que se entendem como sendo de maior relevância norteados pela regra contida no art. 5°, incisos XVII, XVIII, LIV e art. 174 §2° da Constituição Federal;

02) Liminarmente, requer seja deferido o pedido em caráter cautelar, com efeito *ex nunc*, conforme sustentado no item V da presente peça, determinando a manutenção dos contratos de franquia postal vigentes, posteriormente a data de 10/11/2010, até que estes sejam regularizados conforme determina a Lei 11.668/2008, conforme regra prevista nos artigos 6°, inc. III e IV e 7°, considerando a presença do "*fumus boni iuris"* e do "*pericilun in mora"*, confirmado através da verossimilhança das alegações, conforme os fundamentos de fato e de direito supracitados, cuja finalidade é evitar gastos desnecessários por parte da Administração Pública e um mau atendimento para o serviço postal;

03) No mesmo sentido, requer seja deferida cautelar, a fim de que os processos que discutem a constitucionalidade e/ou inconstitucionalidade da Lei 11.668/2008, inclusive aqueles processos vinculados indiretamente, tenham seu julgamento suspenso conforme regra prevista no artigo 21 da Lei 9.868/1999;

04) Em decorrência do deferimento do preceito, seja cominado desde já uma multa penal dia significativa a ser arbitrada pelo Emérito Ministro fixando desde já o prazo para cumprimento do mesmo, conforme regra contida no art. 461§ 5.º e seguintes do CPC, em caso de descumprimento do preceito por parte da ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;

05) Requer ao final seja confirmado o pedido em caráter cautelar;

06) Requer seja julgado procedente a presente Ação Declaratória de Constitucionalidade, a fim de que seja declarado como constitucionais as regras contidas nos artigos, 6°, inc. III e IV, 7° §único e 10° da Lei 11.668/2008;

07) Requer seja deferido todos os meios de provas admitidos em direito, inclusive oportunizando desde já o direito à sustentação oral conforme disposto pela Lei 9.868/1999;

08) Requer seja oficiado a todos os Tribunais Regionais Federais e a Justiça Federal, caso seja este o entendimento desta Excelsa Corte a fim de apurar a veracidade das informações acerca do numero de ações em trâmite, bem como, do número de editais suspensos, aplicando de forma análoga a regra contida no artigo 20°, §2° da Lei 9.868/1999;

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Curitiba, 26 de agosto de 2010.

Marcelo Arthur Menegassi Fernandes	***Ane Gonçalves de Resende Fernandes***
OAB/PR 31.367	***OAB/PR 31.337***